
SUMÁRIO

Teoria Geral da Prova.	4
Conceito.	4
Finalidade da prova.	5
Objeto da Prova.	6
Fontes de Provas, Meio de Provas e Meio de Obtenção de Provas.	7
Fontes de Prova.	7
Meios de Prova.	8
Meios de obtenção de prova.	9
Elementos de prova e resultado da prova.	9
Conclusão.	9
Cadeia de custódia.	9
Conceito.	9
Quebra da cadeia de custódia.	11
Etapas de procedimento da cadeia de custódia.	13
Instrução Processual.	14
Standards probatórios.	15
Classificação das Provas.	17
Classificação quanto ao objeto.	17
Classificação quanto ao valor.	17
Classificação quanto ao sujeito.	18
Classificação com relação aos fatos que se pretende demonstrar.	18
Classificação quanto à previsão legal.	18
Prova emprestada.	20
Compartilhamento de dados fiscais e bancários.	21
Provas produzidas no estrangeiro.	22
Provas Cautelares, Não repetíveis e Antecipadas e Análise do Art. 155, CPP.	23
ônus da Prova.	27
Conceito.	27
ônus da Prova Objetivo e Subjetivo.	28
Distribuição do ônus da Prova.	29
ônus da prova distribuído.	29
ônus da prova exclusivo da acusação.	30
Nível probatório exigido pela defesa.	32

Inversão do ônus da prova.	33
O papel do juiz na gestão da prova.	34
Iniciativa do juiz na fase investigatória.	35
Iniciativa do juiz na fase processual.	36
Sistema de Avaliação das Provas.	37
Sistema da Íntima Convicção.	38
Sistema da prova tarifada.	38
Sistema do livre convencimento motivado.	39
Princípios relativos à Prova Penal.	39
Princípio da proporcionalidade.	39
Proporcionalidade e prova ilícita pro reo.	40
Princípio da proporcionalidade e prova ilícita pro societate.	40
Princípio da comunhão da prova.	41
Princípio da autorresponsabilidade das partes.	41
Princípio da oralidade.	41
Subprincípio da concentração.	42
Subprincípio do imediatismo ou da imediatidade.	42
Subprincípio da identidade física do juiz.	42
Princípio da liberdade probatória.	43
Quanto ao momento da produção da prova.	43
Liberdade quanto ao tema da prova.	44
Liberdade quanto ao meio de prova.	44
Prova vedada / ilegal.	44
Prova ilícita.	45
Distinção entre provas ilícitas e ilegítimas.	45
Prova ilícita e sua admissibilidade.	46
Exceção da boa-fé.	46
Exceção de impugnação.	47
Exceção do erro inóquo.	47
EXCEÇÃO DA PROVA ILÍCITA PRO REO.	47
Exceção da visão ampla / Visão aberta.	48
Serendipidade / encontro fortuito de provas.	49
Teoria dos campos abertos. Open fields doctrine e private searches doctrine.	51
Teoria do risco.	51
exceção da renúncia do interessado.	52
Exceção da limitação da infração constitucional alheia.	52
Exceção da limitação da infração por particulares.	52

Provas ilícitas por derivação.	53
Teoria da fonte independente.	54
Teoria da desconberta inevitável.	54
Teoria do nexo causal atenuado.	55
Inutilização da prova ilícita.	56
Inutilização da prova ilícita no âmbito do tribunal do júri.	57
Juiz contaminado.	57

TEORIA GERAL DA PROVA.

CONCEITO.

O conceito de prova depende diretamente da acepção dada a essa palavra. A doutrina aponta ao menos 04 acepções diferentes motivo pelo qual a conceituação do termo pode variar.

No **conceito instrumental** de prova faz-se referência diretamente aos **objetos que são submetidos à análise do julgador** e, portanto, influenciarão na formação de sua convicção.

A prova também pode ser vista sob o **conceito procedimental** ocasião em que as partes executam a **atividade probatória**, apresentando documentos, objetos, testemunhas e, dessa forma, buscando influenciar na formação da cognição do julgador.

O termo prova também pode ser referir a **atividade lógica** realizada pelo juiz por meio de sua **percepção ou dedução, o que lhe permite chegar a determinadas conclusões**.

Por fim, a prova também pode ser vista como **resultado da atividade probatória**, ocasião em que nos referimos que **um fato está provado, referindo a ausência de dúvida razoável a respeito de determinada matéria**.

A esse respeito, MARINONI com maestria apresenta esse conceito, ocasião em que relata que prova “pode significar os instrumentos de que se serve o magistrado para o conhecimento dos fatos submetidos à sua análise, quando se pode falar em prova documental, prova pericial etc. Também pode representar o procedimento por meio do qual tais instrumentos de cognição se formam e são recepcionados pelo juízo – esse é o espaço em que se alude à produção da prova. De outra parte, prova também pode dar a ideia da atividade lógica, celebrada pelo juiz, para o conhecimento dos fatos (percepção e dedução, na mente de PROTO PISANI). E, finalmente, tem-se como prova ainda o resultado da atividade lógica do conhecimento (Marinoni, et al., 2015).

O **esquema processual penal** funda-se na alegação de fatos, os quais produzem **consequência jurídicas**, como por exemplo, a imposição de pena. A defesa, por sua vez, também alega novos fatos, os quais, ao menos em tese, infirmarão aqueles inicialmente imputados na inicial acusatória, ocorre que o juiz (*julgador*) não conhece esses fatos. É justamente nesse ponto em que reside a atividade probatória, *pois consiste em uma atividade desenvolvida pelas partes, as quais apresentam instrumentos destinados a confirmar a sua versão e infirmar a tese contrária e buscam contribuir para a formação da convicção do magistrado*.

O professor TORNAGHI apresenta, ao menos, 03 conceitos possíveis ao termo prova:

Prova como **atividade probatória**. Trata-se de direito das partes a exercer a atividade probatória, mediante o conjunto de atividade de verificação e demonstração na busca da verdade dos fatos.

Prova **como meio**. São os instrumentos idôneos e capazes de contribuir efetivamente à convicção do julgador.

Prova **como resultado**. Fala-se na formação de um **conhecimento processualmente verdadeiro**. As provas referem-se a fatos passados, por essa razão não é possível reconstituí-los com perfeição. Por essa razão não se utiliza mais a expressão

verdade real, sugerindo-se a utilização do termo verdade possível, ou verdade além da dúvida razoável.

Por fim, **não se deve confundir as provas com os elementos informativos**. Os elementos informativos surgem das investigações preliminares e possuem finalidades próprias, dentre as quais, a formação da convicção do magistrado apresenta-se somente como finalidade mediata ou secundária.

Os elementos informativos são produzidos com base em um sistema inquisitivo no qual não há aplicabilidade plena do contraditório e da ampla defesa. Já as provas, submetem-se a criterioso procedimento de contraditório e ampla defesa.

A partir da leitura do artigo 155, CPP, percebe-se que os elementos informativos até podem contribuir na formação da convicção do magistrado, desde que, caso seja um juízo condenatório, seja alicerçada em provas e não somente nesses elementos.

A esse respeito, vejamos as lições apresentadas por Eugênio Pacelli (Pacelli, et al., 2021):

Rigorosamente falando, o material produzido na fase de investigação não pode ser considerado prova. Ao menos, em princípio. A fase de investigação, como se sabe, é destinada à formação do convencimento do órgão da acusação e não do magistrado. Na aludida fase, não há preocupação com o contraditório, até mesmo porque sequer se exerce a defesa do acusado. Não há ali, à evidência, ampla defesa. A partir de uma notitia criminis, avança-se para uma apuração sumária de seus elementos comprobatórios, sempre voltada para o convencimento do órgão responsável pelo juízo acusatório. Esse, o juízo acusatório, pode ser positivo, em que há o oferecimento da denúncia ou queixa, ou negativo, hipótese em que se requer o arquivamento da investigação, quaisquer que sejam os seus fundamentos. Apenas o material produzido em Juízo é que, a rigor, constituiria prova, abrindo-se necessariamente ao contraditório e à ampla defesa, com efetiva participação da defesa. Em princípio, portanto, apenas a prova se prestaria ao convencimento judicial, não cumprindo essa missão os chamados elementos informativos da fase investigatória.

FINALIDADE DA PROVA.

A atividade probatória tem por **principal finalidade o convencimento do juiz a respeito da existência ou inexistência de fatos que gerarão consequências jurídicas contidas em sua decisão**.

Desse modo, conforme posicionamento preponderante na doutrina, a finalidade da prova é a formação da convicção do juiz.

Essa reconstrução ocorre internamente, dentro da relação processual, motivo pelo qual se fala em verdade processual, o conceito de verdade real é inatingível e o é por diversos motivos.

A respeito dos destinatários da prova, sem dúvida, o principal alvo da atividade probatória é o magistrado, contudo, ao menos de forma secundária, as partes também, além de produtores, também são alvos da atividade probatória, pois se, além do juiz, as partes forem convergentes, a pacificação social, alvo direto da jurisdição, estará mais próxima de ser atingida.

Há de se observar que alguns doutrinadores já falam sobre consensualidade na produção da prova penal, tema que pode aparecer em provas discursivas e orais. Nesse ponto, sugerimos a interessante leitura da tese de mestrado do professor Rafael Estrela Nóbrega.¹

OBJETO DA PROVA.

O objeto da prova é **o “*thema probandum*”**. Trata-se daquele **acontecimento, fato ou circunstância que deve ser demonstrado e, uma vez conhecido pelo julgador, o autoriza a decidir sobre a questão submetida a julgamento.**

NORBERTO AVENA diz que objeto da prova “são os fatos, principais ou secundários, que reclamem uma apreciação judicial e exijam uma comprovação” (Avena, 2020). “Objeto da prova são, primordialmente, **os fatos que as partes pretendem demonstrar**. Excepcionalmente, a parte deve fazer **prova quanto à existência e ao conteúdo de um preceito legal**, desde que se trate de norma internacional, estadual ou municipal (nestes últimos dois casos, caso se trate de unidade da Federação diversa daquela onde está o magistrado)” (Nucci, 2018).

RENATO BRASILEIRO, em sentido diverso, relata que não são diretamente os fatos que se constituem como objeto de prova, mas, na verdade, a verdade ou falsidade dos fatos que interessam à solução do processo.

A esse respeito, uma pergunta se faz necessária:

O que deve ser objeto de prova no processo penal?

Ainda valendo-se das lições de RENATO BRASILEIRO:

Imputação constante na inicial acusatória ou mesmo fatos que excluam a ilicitude da conduta.
Costumes.

Regulamentos e Portarias.

Direito estrangeiro, estadual e municipal.

Fatos não contestados ou incontroversos.

Outro questionamento se faz necessário:

Aplica-se integralmente, por analogia, as disposições do artigo 374, CPC, ao processo penal?

Inicialmente, veja a redação do referido artigo:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

¹ https://www.btdt.uerj.br:8443/bitstream/1/9808/1/Rafael%20Estrela%20Nobrega_Total.pdf

A doutrina penalista aponta que possuem aplicabilidade em relação ao processo penal somente os incisos I e IV. A esse respeito, vejamos as lições apresentadas pelo professor Renato Brasileiro (Lima, 2021):

De acordo com o art. 374, II e III, do novo CPC, não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária ou aqueles admitidos, no processo, como incontroversos. Além disso, referindo-se à revelia, dispõe o CPC que, se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor (NCPC, art. 344). No âmbito processual penal, por força do princípio da presunção de inocência, mesmo que o acusado venha a confessar a prática do delito, subsiste o ônus da acusação de comprovar a imputação constante da peça acusatória. Nessa linha, segundo o art. 197 do CPP, “o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância”. Ademais, mesmo que seja decretada a revelia do acusado com fundamento no art. 367 do CPP, não há falar em confissão ficta ou presumida no processo penal, com a consequente presunção da veracidade dos fatos narrados na peça acusatória. Mesmo na hipótese de acusado revel, ainda assim deverá o órgão ministerial desincumbir-se a contento de seu ônus probatório, sob pena de o pedido condenatório ser julgado improcedente pelo julgador).

Por outro lado, de fato, a doutrina aponta alguns fatos que independem de prova, são eles:

- Fatos axiomáticos. São conhecimentos que derivam do conhecimento comum, rotineiro. Ex. Não é necessário provar que o fogo queima.

Fatos notórios.

Fatos inúteis.

Presunções legais. Ex. inimputabilidade dos menores de 18 anos.

Para o professor Edilson Mougnot Bonfim também independem de prova as denominadas **máximas experiências**: *conjunto de experiências adquiridos pelo juiz em razão de sua experiência irreversível.*

FONTES DE PROVAS, MEIO DE PROVAS E MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVAS.

Inicialmente, é importante observar que a doutrina clássica não trata da distinção entre fontes de prova e meios de prova, a exemplo dos professores José Frederico Marques e Hélio Tornaghi, vejamos algumas lições a respeito dessa indistinção:

“como ensina PONTES DE MIRANDA, são as fontes probantes, os meios pelos quais o juiz recebe os elementos ou motivos de prova. Através deles é que o magistrado forma a sua convicção e as partes procuram demonstrar os fatos que alegaram” (Marques, 1997).

Por outro lado, a doutrina moderna, a exemplo do professor Renato Brasileiro, exploram bem a diferença entre fontes, meios e meios de obtenção de prova. As provas de concursos também têm explorado essa diferenciação, motivo pelo qual iremos analisar a distinção de forma detida.

FONTES DE PROVA.

As fontes de prova **são os objetos, pessoas, coisas ou documentos de onde advém a prova**. Trata-se de tudo que é passível de oferecer conteúdo apreciável pelo juiz, a exemplo de uma pessoa, um documento ou coisas.

São **anteriores ao processo** e, portanto, **extraprocessuais**, somente após migrarem para dentro do processo e submeterem-se ao contraditório, passam a serem chamadas como meios de prova.

Renato Brasileiro esclarece que a “expressão fonte de prova é utilizada para designar as pessoas ou coisas das quais se consegue a prova, daí resultando a classificação em **fontes pessoais** (ofendido, peritos, acusado, testemunhas) e **fontes reais** (documentos, em sentido amplo). Cometido o fato delituoso, tudo aquilo que possa servir para esclarecer alguém acerca da existência desse fato pode ser conceituado **como fonte de prova**. Derivam do fato delituoso em si, independentemente da existência do processo, ou seja, são anteriores a ele, sendo que sua introdução no feito se dá através dos meios de prova.” (Lima, 2021).

MEIOS DE PROVA.

Os meios de prova **são efetivamente a forma pela qual as informações advindas das fontes de prova são introduzidas ao processo**. Trata-se, ao contrário das fontes de prova, de **elemento endoprocessual** que tem por finalidade fixar as informações no âmbito do processo.

Mais uma vez, valemo-nos das lições apresentadas pelo mestre Renato Brasileiro:

*[...] meios de prova são os instrumentos através dos quais as fontes de prova são introduzidas no processo. Dizem respeito, portanto, a uma atividade endoprocessual que se desenvolve perante o juiz, com o conhecimento e a participação das partes, cujo objetivo precípuo é a fixação de dados probatórios no processo. Enquanto as fontes de prova são anteriores ao processo e extraprocessuais, os meios de prova somente existem no processo. **Como aduz BADARÓ, "a testemunha de um fato é a fonte de prova, enquanto suas declarações em juízo são o meio de prova. O documento é uma fonte de prova, a sua incorporação ao processo é o meio de prova. O livro contábil é a fonte de prova, enquanto a perícia contábil é o meio de prova"**. Os meios de prova podem ser lícitos ou ilícitos. Somente os primeiros podem ser admitidos pelo magistrado, dispondo o art. 157 do CPP que são inadmissíveis as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais, devendo ser desentranhadas dos autos do processo.*

Nosso leitor poderia estar se questionando:

Professor, qual é o sentido dessa distinção? Qual o fundamento?

A distinção seria justamente **a compatibilização da atividade complementar do juiz na produção probatória e sua compatibilização com o sistema acusatório**. Observe que o juiz não pode procurar, investigar e, conseqüentemente, localizar fontes de provas, contudo, caso tenha notícia dessas fontes, ele poderia, a título complementar, determinar a sua introdução no processo.

Vejamos o exemplo apresentado pelo professor MADEIRA (Dezem, 2018):

Por exemplo, havendo dúvida sobre um fato relevante, e existindo no boletim de ocorrência o nome de uma testemunha presencial, o juiz, tendo conhecimento da existência de tal fonte de prova (a testemunha), poderá determinar a produção do meio de prova correspondente (o depoimento da testemunha em juízo). Além disso, ao determinar a produção do meio de prova, o juiz não sabe, de antemão, qual o resultado probatório que poderá advir da produção de tal meio de prova: positivo, negativo ou inconclusivo. Por exemplo, poderá comprovar ter sido o acusado o autor do crime, poderá comprovar que não foi o acusado o autor do crime, ou poderá não fornecer elementos de prova seguros sobre a autoria delitiva.

MEIOS DE OBTENÇÃO DE PROVA.

Os **meios de obtenção de prova se destinam a localizar e investigar as fontes de provas e introduzi-las no âmbito processual**. Pode-se citar, a título de exemplo, as medidas de busca e apreensão, a interceptação telefônica, a quebra de sigilo financeiro ou bancário ou mesmo a infiltração de agentes.

Em regra, são executados na fase pré-processual por agentes policiais, valendo-se do elemento surpresa para a sua produção. Caso sejam praticadas em desconformidade com a Lei, deve ser reconhecida a sua inadmissibilidade no âmbito do processo.

CONCLUSÃO.

Poderíamos então chegar a seguinte síntese a respeito das informações acima tratadas:

<u>Meios de Obtenção de Prova.</u>	<u>Fontes de Prova.</u>	<u>Meios de Prova.</u>
Busca e apreensão.	Drogas localizadas e apreendidas.	Exame pericial definitivo.
Localização de testemunhas do delito.	Pessoas arroladas como testemunhas.	Depoimento.

CADEIA DE CUSTÓDIA.

CONCEITO.

O conceito de cadeia de custódia pode ser extraído das próprias disposições legais, vejamos:

Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. [\(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019\)](#)

A doutrina também apresenta a sua conceituação a respeito da cadeia de custódia. Norberto Avena relata que é “*caminho percorrido pela prova desde o conhecimento da prática de uma infração pelas autoridades encarregadas da persecução criminal até o momento em que, constatada a ocorrência de vestígios e realizados os exames necessários, for produzido o laudo pericial e descartado o material que serviu de base para a perícia*” (Avena, 2020).

Renato Brasileiro esclarece que se trata de “*mecanismo garantidor da autenticidade das evidências coletadas e examinadas, assegurando que correspondem ao caso investigado, sem que haja lugar para qualquer tipo de adulteração. Funciona, pois, como a documentação formal de um procedimento destinado a manter e documentar a história cronológica de uma evidência, evitando-se, assim, eventuais interferências internas e externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória*”.

Dessas informações, pode-se concluir que a cadeia de custódia se **constitui em um procedimento, legalmente definido, destinado a garantir que o vestígio coletado no local do crime seja o mesmo que será submetido a análise pericial sem que haja nenhuma interferência, substituição ou alteração em sua estrutura.**

A esse respeito, o CPP cuidou de conceituar, legalmente, o termo vestígio como “*todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal.*”

O tema tem sido frequentemente cobrado em prova:

() Promotor de Justiça – 2024/MPMS - Considera-se vestígio todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal.

A ideia da cadeia de custódia é garantir a lisura dos vestígios, normalmente, constituindo-se em objeto de prova pericial. É nítido que, no sistema da persuasão racional do juízo, adotado no ordenamento jurídico brasileiro, **não existe hierarquia entre os diversos meios de prova.**

Por outro lado, **não se nega a credibilidade e confiabilidade advinda de prova pericial**, essencialmente aquelas produzidas no curso da investigação. Dessa maneira, é inegável o cuidado que se deve ter em relação aos vestígios coletados nos locais de crime e sua posterior submissão a análise pericial.

A proteção dada ao local de crime foi tamanha que o CPP passou a tratar como crime a conduta de violar o local de crime, vejamos as disposições:

Art. 158-C. § 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização.

CP.

Art. 347 - Inovar artificialmente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito.

Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa.

Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.

Busca-se com a efetivação da cadeia de custódia, a possibilidade de **garantir a sindicabilidade da prova técnica**. Vários dispositivos do CPP, tratam a respeito desse cuidado com os vestígios contidos nos locais de crime.

Art. 6º Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá:

*I - dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais;
II - apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais;*

Art. 169. Para o efeito de exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos.

Parágrafo único. Os peritos registrarão, no laudo, as alterações do estado das coisas e discutirão, no relatório, as consequências dessas alterações na dinâmica dos fatos.

Art. 170. Nas perícias de laboratório, os peritos guardarão material suficiente para a eventualidade de nova perícia. Sempre que conveniente, os laudos serão ilustrados com provas fotográficas, ou microfotográficas, desenhos ou esquemas.

QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.

Conforme já analisado, a cadeia de custódia busca garantir a autenticidade do vestígio, a qual, conforme Cunha, pode ser conceituada como a certeza de que o objeto em análise provém das fontes anunciadas e que não foi alvo de mutações ao longo de um processo, assegurando-se a identificação e a segurança da origem da informação.

Antes de efetivamente tratarmos dos efeitos da quebra da cadeia de custódia, é interessante observar que o STJ posiciona-se no sentido de que “a cadeia de custódia da prova consiste no caminho que deve ser percorrido pela prova até a sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência indevida durante esse trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (STJ. 5ª Turma. RHC 77.836/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 05/02/2019).

Outro ponto relevante diz respeito a necessidade de se demonstrar concretamente elementos que indiquem a adulteração ou manipulação das provas:

*AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. RECEPÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. **QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA**. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.*

*A alegação da **quebra da cadeia de custódia** deve estar corroborada com outros elementos que indiquem adulteração ou*

manipulação de provas, o que não se verifica, de plano, no presente caso.

Precedentes.

Ademais, para se alcançar tal reconhecimento seria inevitável reanálise de todo o acervo fático e probatório que instrui os autos, providência, como é sabido, inadmissível em sede de habeas corpus.

Precedentes.

Agravo regimental não provido.

(5ª Turma, Ministra Daniela Teixeira, julgada em 01/07/2024).

No início do ano de 2025, o STJ (AgRg no HC 919616 / AL AGRADO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS, 5ª Turma, julgado 19/02/2025, publicado em 25/02/3035) continua decidindo nesse sentido, vejamos:

*Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUEBRA DA **Cadeia de custódia**. Alegação genérica de nulidade. não acolhimento. Recurso DESprovido.*

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu o habeas corpus, no qual se alegava quebra da cadeia de custódia de provas, especificamente em relação ao manuseio de celular da vítima pela polícia, sem indicação concreta de adulteração.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de quebra da cadeia de custódia, sem a apresentação de elementos concretos que indiquem adulteração das provas, é suficiente para declarar sua nulidade.

III. Razões de decidir 3. A Corte de origem refutou a nulidade apontada pela defesa, destacando a ausência de elementos concretos que sugerissem adulteração das provas ou alteração da ordem dos diálogos.

4. A defesa não apresentou elementos capazes de desacreditar a preservação das provas produzidas, conforme destacado no acórdão impugnado.

5. Desconstituir o entendimento demandaria reexame de conjunto fático e probatório, inviável em sede de habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental des provido.

Tese de julgamento: "1. A alegação de quebra da cadeia de custódia deve ser acompanhada de elementos concretos que indiquem adulteração das provas. 2. A ausência de tais elementos inviabiliza a declaração de nulidade das provas." Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 858.508/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13.06.2024; STJ, AgRg no HC 825.126/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 11.09.2024.

Um interessante questionamento a respeito do assunto é o seguinte:

Quais os efeitos da quebra da cadeia de custódia (break in the chain of custody)?

A respeito dos efeitos advindos da quebra da cadeia de custódia, duas correntes se formaram:

1ª Corrente → A quebra da cadeia de custódia gera a ilicitude imediata dos vestígios e, eventualmente, da prova advinda da análise.

2ª Corrente → A quebra **não gera a ilicitude / nulidade imediata**, contudo **a valoração pericial do vestígio poderá ter maior ou menor valor, a depender da intensidade da violação da cadeia.**

A esse respeito, o STJ também se manifestou no mês de fevereiro de 2025 (AgRg no HC 924130 / SE AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS, 5ª turma, julgado em 12/02/2025), vejamos:

(...)

*Razões de decidir 4. A quebra da **cadeia de custódia** não configura nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova. A defesa não comprovou adulteração da prova ou intercorrências no seu iter.*

5. O relatório de investigação produzido por policiais civis é válido, pois se trata de documento descritivo que não requer expertise técnica específica.

6. A sentença de pronúncia pode se basear em provas cautelares e não repetíveis, que possuem eficácia probatória sem necessidade de confirmação no curso da ação penal, conforme art. 155 do CPP.

7. No caso, a sentença de pronúncia fundamentou-se em provas da materialidade e indícios de autoria, incluindo laudo pericial e depoimentos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido.

*Tese de julgamento: "1. A quebra da **cadeia de custódia** não configura nulidade processual, mas afeta a eficácia da prova, devendo ser comprovada a adulteração para invalidá-la. 2. Provas cautelares e não repetíveis possuem eficácia probatória sem necessidade de confirmação no curso da ação penal, conforme art. 155 do CPP."*

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155.

Esse posicionamento tem prevalecido em provas, Na prova no Ministério Público do Espírito Santo, no final do ano de 2025, foi cobrada a seguinte questão:

() Autorizada judicialmente, a Polícia Civil realiza diligência de busca e apreensão na casa de Pedro, funcionário público investigado por suspeita de participação em organização criminosa voltada à prática de fraudes em licitações. No local, o policial civil Renato apreende documentos de interesse para a investigação, os acondiciona em recipiente próprio e o lacra. Em seguida, preenche a ficha de acompanhamento de vestígio (FAV). Já na Delegacia, Renato nota que o lacre se rompeu e o substitui, sem registrar o fato na FAV. A inconsistência entre os números do lacre é debatida na ação penal posteriormente proposta em face de Pedro. Renato é ouvido como testemunha e esclarece o acontecido. Pedro é condenado. A esse respeito, a

quebra da cadeia de custódia diz respeito à credibilidade da prova e não implica nulidade processual.²²

Parece-nos que a segunda corrente possui prevalência. Observe as lições apresentadas por Renato Brasileiro:

Ao fim e ao cabo, resta analisarmos as consequências decorrentes da quebra da cadeia de custódia. De um lado, há quem entenda que a quebra inviabiliza o efetivo exercício do contraditório pela parte que não tem acesso à prova integral. Sob a ótica da teoria dos frutos da árvore envenenada, os elementos remanescentes serão contaminados, logo, ilícitos, em virtude da lacuna decorrente da supressão de outros elementos que poderiam configurar argumentos persuasivos em sentido contrário à tese deduzida no processo. Houve, portanto, violação ao contraditório, como condição de validade constitucional, daí porque há de se reconhecer a ilicitude da prova remanescente, nos termos do art. 157 do CPP. Em sentido diverso, com a introdução do regramento atinente à cadeia de custódia pela Lei n. 13.964/2019, parte da doutrina prefere afirmar que eventual violação à nova sistemática adotada pelos arts. 158-A a 158-F do CPP poderá acarretar a ilegitimidade da prova, haja vista a violação a regras de direito processual, com a consequente aplicação da teoria das nulidades (nossa posição) (Lima, 2021).

Leonardo Barreto também adere à segunda corrente:

“É dizer, a quebra da cadeia de custódia não resulta, necessariamente, em prova ilícita ou ilegítima, interferindo apenas na valoração dessa prova pelo julgador. A irregularidade na cadeia de custódia reduzirá a credibilidade da prova, diminuirá o seu valor, passando-se a ser exigido do juiz um reforço justificativo caso entenda ser possível confiar na integridade e na autenticidade da prova e resolva utilizá-la na formação do seu convencimento.

Enfim, “a quebra da cadeia de custódia não significa de forma absoluta, a inutilidade da prova colhida. É preciso não se esquecer que a cadeia de custódia existe não para provar algo, mas para garantir uma maior segurança – dentro do possível – à colheita, ao armazenamento e à análise pericial da prova [...]. Desta forma, a análise do elemento coletado e periciado, se houver quebra dos procedimentos de cadeia de custódia, interferirá apenas e tão somente na valoração dessa prova pelo julgador”. (Manual de Processo Penal. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 754).

A 2ª Turma do STJ já se manifestou nesse sentido:

As irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável.

STJ. 6ª Turma. HC 653.515-RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 23/11/2021 (Info 720).

²² Gabarito> Certo.

Apesar desse posicionamento, o qual deve ser mantido em termo gerais e genéricos, analisando casuisticamente, observa-se que o STJ tem decidido que vícios na cadeia de custódia tem inviabilizado o uso da prova objeto de violação, ainda que não gere automaticamente a nulidade do processo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. OCORRÊNCIA. SEM EFEITO NA CONDENAÇÃO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ENDEREÇO DIVERSO. LEGALIDADE. INFORMAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO PELA GENITORA DO INVESTIGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Dispõe o art. 563 do CPP que "[n]enhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

2. No caso em tela, os policiais, munidos de mandado de busca e apreensão, primeiramente realizaram busca no veículo do ora agravante, onde encontraram 63 eppendorfs contendo cocaína e 3 invólucros de maconha em uma sacola e, posteriormente, localizaram mais drogas na sua residência.

3. A sacola que continha as drogas no veículo foi descartada pelos agentes policiais e trocada por outra, em clara quebra da cadeia de custódia, atestada em laudo pericial que demonstrou ser impossível coletar as impressões digitais no material.

4. Entretanto, dado que foram encontradas drogas na residência do agente de forma independente, em razão de cumprimento de mandado de busca e apreensão previamente expedido, não há de se falar em anulação de toda a ação penal porquanto em nada aproveitaria à defesa. AgRg no RHC 195921 / MG AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2024/0110023-1, julgado em 06/06/2024, Relator: Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma.
(...).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE CELULAR. EXTRAÇÃO DE DADOS. CAPTURA DE TELAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INADMISSIBILIDADE DA PROVA DIGITAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. O instituto da cadeia de custódia visa a garantir que o tratamento dos elementos probatórios, desde sua arrecadação até a análise pela autoridade judicial, seja idôneo e livre de qualquer interferência que possa macular a confiabilidade da prova.

2. Diante da volatilidade dos dados telemáticos e da maior suscetibilidade a alterações, imprescindível se faz a adoção de mecanismos que assegurem a preservação integral dos vestígios probatórios, de forma que seja possível a constatação de eventuais alterações, intencionais ou não, dos elementos inicialmente coletados, demonstrando-se a higidez do caminho percorrido pelo material.

3. A auditabilidade, a repetibilidade, a reprodutibilidade e a

justificabilidade são quatro aspectos essenciais das evidências digitais, os quais buscam ser garantidos pela utilização de metodologias e procedimentos certificados, como, e.g., os recomendados pela ABNT.

4. A observação do princípio da mesmidade visa a assegurar a confiabilidade da prova, a fim de que seja possível se verificar a correspondência entre aquilo que foi colhido e o que resultou de todo o processo de extração da prova de seu substrato digital. Uma forma de se garantir a mesmidade dos elementos digitais é a utilização da técnica de algoritmo hash, a qual deve vir acompanhada da utilização de um software confiável, auditável e amplamente certificado, que possibilite o acesso, a interpretação e a extração dos dados do arquivo digital.

5. De relevo trazer à baila o entendimento majoritário desta Quinta Turma no sentido de que "é ônus do Estado comprovar a integridade e confiabilidade das fontes de prova por ele apresentadas. É incabível, aqui, simplesmente presumir a veracidade das alegações estatais, quando descumpridos os procedimentos referentes à cadeia de custódia" (AgRg no RHC n. 143.169/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2023).

*6. Neste caso, não houve a adoção de procedimentos que assegurassem a idoneidade e a integridade dos elementos obtidos pela extração dos dados do celular apreendido. Logo, evidentes o prejuízo causado pela **quebra da cadeia de custódia** e a imprestabilidade da prova digital.*

7. Agravo regimental provido a fim de conceder a ordem de ofício para que sejam declaradas inadmissíveis as provas decorrentes da extração de dados do celular do corrêu, bem como as delas decorrentes, devendo o Juízo singular avaliar a existência de demais elementos probatórios que sustentem a manutenção da condenação. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, T5 - QUINTA TURMA, 23/04/2024 DJe 29/04/2024.

Conforme apontado pelo site Dizer o Direito em comentários ao julgado do STJ, o referido tribunal entendeu que são inadmissíveis as provas digitais sem registro documental acerca dos procedimentos adotados pela polícia para a preservação da integridade, autenticidade e confiabilidade dos elementos informáticos.

No mesmo sentido:

A quebra da cadeia de custódia, em razão da falta de numeração individualizada do material objeto da perícia definitiva, que resulte na impossibilidade de se distinguir, com segurança, se a reconhecida inconsistência de parte da perícia, relativa a natureza entorpecente do material apreendido, referia-se às substâncias apreendidas por ocasião da busca pessoal ou das provas declaradas ilícitas por desrespeito à inviolabilidade domiciliar, acarreta a absolvição do acusado por falta de materialidade delitiva.

STJ. 6ª Turma. REsp 2.024.992-SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, julgado em 5/3/2024 (Info 803).³

Ainda a esse respeito, posicionamento da 5ª Turma:

Não há como assegurar que os elementos informáticos periciados pela polícia e são íntegros e idênticos aos que existiam nos computadores do réu, o que acarreta ofensa ao art. 158 do CPP com a quebra da cadeia de custódia dos computadores apreendidos pela polícia, inadmitindo-se as provas obtidas por falharem num teste de confiabilidade mínima.

STJ. 5ª Turma. RHC 143169/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Rel. Acd. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 7/2/2023 (Info 763).

Veamos a questão de prova cobrada no ano de 2026:

Em uma investigação sobre crimes contra a honra praticados pela internet, a autoridade policial cumpriu mandado de busca e apreensão e apreendeu um notebook na residência do investigado.

O perito criminal, ao invés de espelhar o disco rígido (HD) do aparelho para análise, limitou-se a ligar o computador e a fotografar as telas que continham as supostas conversas ofensivas, juntando as fotografias ao laudo pericial.

Sobre a validade da prova produzida, considerando a disciplina da cadeia de custódia no Código de Processo Penal e o entendimento jurisprudencial dominante no Superior Tribunal de Justiça (STJ), assinale a afirmativa correta.

A A prova é válida, pois as normas sobre cadeia de custódia, previstas no Código de Processo Penal, são direcionadas exclusivamente a vestígios físicos, não se aplicando à prova digital, cuja natureza volátil justifica um tratamento processual diferenciado e menos rigoroso.

B A prova é irregular, mas não ilícita, sendo passível de convalidação em juízo caso a defesa não impugne o laudo pericial no momento oportuno, o que acarreta a preclusão, tornando a evidência plenamente utilizável no processo.

C A quebra da cadeia de custódia da prova digital torna a evidência inadmissível, pois compromete sua integridade e sua autenticidade, não sendo possível assegurar que o material analisado é o mesmo do que foi coletado.

D A falta de espelhamento do disco rígido (HD) é uma simples irregularidade, que pode ser suprida pela oitiva do perito em juízo, cujo depoimento, dotado de fé pública, é suficiente para confirmar a autenticidade das imagens e a correspondência com o material originalmente apreendido.

E A prova é ilícita, mas a nulidade é relativa, exigindo que a defesa demonstre o prejuízo concreto sofrido pelo acusado, como a prova de que as imagens foram adulteradas.

³ CAVALCANTE, Márcio André Lopes. A mera inobservância do procedimento de cadeia de custódia previsto CPP não acarreta, automaticamente, a imprestabilidade das provas colhidas; a consequência processual dependerá da análise do caso concreto. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/89f8f214774c7ec55bdbf7912c9ee04a>>. Acesso em: 12/08/2024

Em 16/06/2026, a 5ª Turma do STJ manifestou-se no sentido de que a preservação da cadeia de custódia abrange não só a integralidade da prova, mas a possibilidade de acesso integral e contemporâneo da prova.

1. A defesa tem o direito de acessar não apenas a prova selecionada pela acusação para fundamentar a denúncia, mas também o material probatório mantido sob custódia estatal que possa contextualizar, contradizer ou enfraquecer a hipótese acusatória.

2. A reabertura de prazo para complementação das alegações finais permite manifestação formal posterior, mas não recompõe a oportunidade de utilizar a prova desde a resposta à acusação e durante a instrução processual.

3. A declaração judicial de que as gravações não fundamentaram a condenação não torna irrelevante a falta de acesso integral ao acervo, pois a defesa tem direito de verificar se a narrativa acusatória foi construída a partir de leitura parcial, incompleta ou descontextualizada da fonte probatória.

[AREsp 3.028.845-PR](#), Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 16/6/2026, DJEN 23/6/2026.

A controvérsia consiste em definir:

(i) se a juntada de gravações ambientais apenas após a instrução e as alegações finais, embora antes da sentença e com reabertura de prazo para manifestação defensiva, assegura contraditório efetivo e acesso integral à prova mantida sob custódia estatal; e

(ii) se a ausência de acesso integral e tempestivo às gravações ambientais compromete a cadeia de custódia, a confiabilidade do acervo probatório e impõe a nulidade dos atos processuais a partir da resposta à acusação.

Ora, a cadeia de custódia da prova digital não se esgota na preservação da integridade, tomada como ausência de adulteração do conteúdo. Ela também envolve a integralidade do corpo de delito, isto é, a preservação do conjunto probatório de modo completo, contextualizado e submetido a controle pelas partes. Uma prova pode não apresentar sinal de adulteração e, ainda assim, ser processualmente problemática se chegar ao contraditório como fragmento de um acervo mais amplo, cuja completude não foi demonstrada.

Em 06/05/2026, o STJ contou com outra manifestação relevante no seguinte sentido:

1. A realização de cópia por espelhamento de dados utilizando-se da função matemática *hash* é instrumento hábil para garantir a integridade e a auditabilidade da evidência imaterial.

2. O agente policial pode realizar a verificação e a coleta preliminar de dados em aparelho celular durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, sem a necessidade imediata da participação de um perito oficial.

[Inq 1.674-DF](#), Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 6/5/2026, DJEN 14/5/2026.

Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a consequência processual concreta de eventual desconformidade com as regras previstas no Código de Processo Penal para as etapas de rastreamento dos vestígios (158-A a 158-F) dependerá do cotejo com os demais elementos de prova constantes dos autos.

Prevalece, no STJ, o entendimento de que a questão em torno da observância da cadeia de custódia não guarda relação com as nulidades processuais, mas, sim, com a eficácia da prova, a ser analisada na situação concreta e à luz dos demais elementos produzidos na instrução.

Ademais, no que concerne à alegada inexistência da cadeia de custódia quanto ao *iPad* do denunciado, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou, nos autos do AgRg no *Habeas Corpus* 242.158-SP (julgado em 1º/7/2024), arguição de quebra da cadeia de custódia e decidiu que o agente policial pode realizar a verificação e a coleta preliminar de dados em aparelho celular durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, sem a necessidade imediata da participação de um perito oficial.

A atuação do agente policial, com esteio nos arts. 158-A, §§ 1º e 2º, e 158-B, I, todos do CPP, limita-se a verificar, nessas situações, se o celular encontrado no momento da busca possui capacidade de armazenar informações relacionadas ao crime investigado.

As fases de reconhecimento e coleta (art. 158-B, I e IV, do CPP), entre outros atos preliminares, ocorrem antes da perícia técnica oficial prevista no art. 159 do CPP, razão pela qual esses procedimentos podem ser realizados sem a intervenção imediata de um perito oficial, não havendo que se falar em nulidade ou ilegalidade na manipulação do dispositivo por parte do agente policial.

A finalidade da busca e apreensão do aparelho celular (na situação dos autos, um *tablet*) não está relacionada ao próprio aparelho, mas aos dados existentes no equipamento, razão pela qual se consolidou o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça de que a apreensão do telefone pressupõe o acesso aos dados nele armazenados.

Em 16/03/2026, o STJ já havia no sentido de possibilitar a busca exploratória no local de crime diante de mídias digitais, sem que isso macule a cadeia de custódia, vejamos:

A extração de provas do celular do réu, em razão do manuseio e acesso pela polícia antes da perícia técnica, não implica quebra da cadeia de custódia, ainda que sem registro, documentação ou controle das atividades que se empreenderam. unanimidade, julgado em 10/3/2026, DJEN 16/3/2026.

Na hipótese, o que se tem é um contexto de realização de diligências de busca e apreensão regularmente deferidas, com análises preliminares pela Polícia, a fim de aferir a relevância do material apreendido, e posterior entrega para a perícia, havendo notícia da existência dos registros do caminho percorrido pela prova e da observância do processo de garantia de integralidade dos arquivos das mídias, conforme os laudos periciais. Frise-se que as provas permaneceram sob custódia policial até o encaminhamento para perícia.

Por fim, um outro julgado relevante no que concerne à prova, apesar de não trata-se especificamente da cadeia de custódia, diz respeito a possibilidade de utilização de IA para confecção de relatório policial:

O Relatório produzido por investigador de polícia com a utilização de ferramentas de inteligência artificial generativa não possui confiabilidade epistêmica mínima para ser utilizado como prova no processo penal. [HC 1.059.475-SP](#), Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 7/4/2026.

A temática da preservação de provas digitais tem sido tema bastante quente em provas. O assunto foi cobrado na prova do TRF 5ª Região para a prova de Juiz Federal no ano de 2025, vejamos⁴:

Em relação às provas digitais, assinale a alternativa correta:

A Considera-se prova digital qualquer informação produzida, armazenada ou transmitida por meios eletrônicos, incluindo os elementos nascidos em formato digital, mas não aqueles originalmente analógicos que foram digitalizados posteriormente.

B A preservação da cadeia de custódia das provas digitais tem a finalidade de garantir sua integridade e sua autenticidade, sendo que uma das etapas consiste em realizar cópias espelho e cálculo da função hash.

C A preservação da cadeia de custódia das provas digitais tem a finalidade de garantir sua autenticidade e tornar inacessíveis as informações para terceiros estranhos à investigação, assegurando sua força probatória e relevância.

D Todo o material digital coletado deve ser preservado, periciado e, posteriormente, inserido no sistema judicial eletrônico, a fim de garantir a publicidade e o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes envolvidas.

E Nas diligências de investigação das evidências digitais é imprescindível a apreensão dos equipamentos para que, posteriormente, a defesa tenha acesso a todo o conteúdo, o que dispensa a necessidade de cópia de segurança.

ETAPAS DE PROCEDIMENTO DA CADEIA DE CUSTÓDIA.

É importante observar que a cadeia de custódia tem início antes mesmo da persecução penal, com a percepção sobre a existência do vestígio e a preservação do local de crime, conforme se pode extrair da leitura do artigo 158, §1º, CPP:

Art. 158.

(...)

§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.

No mesmo sentido, a lei outorga ao agente público que reconhecer um vestígio, o dever de preservá-lo:

Art. 158.

(...)

§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.

O CPP passou a prever detalhadamente cada uma das fases da cadeia de custódia, observe:

Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas: [\(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019\)](#)

I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial; [\(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019\)](#)

⁴ Gabarito: B

II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime; [\(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019\)](#)

III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento; [\(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019\)](#)

IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e natureza; [\(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019\)](#)

V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento; [\(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019\)](#)

VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse; [\(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019\)](#)

VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu; [\(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019\)](#)

VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito; [\(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019\)](#)

IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente; [\(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019\)](#)

X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial. [\(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019\)](#)

No âmbito do artigo 158-C, duas disposições são importantes, vejamos inicialmente a literalidade do dispositivo:

Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada **preferencialmente por perito oficial**, que dará o encaminhamento necessário para **a central de custódia**, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares.

§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.

§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização.

Os demais dispositivos a respeito da cadeia de custódia são autoexplicativos, motivo pelo qual se propõe detida leitura e análise dos dispositivos legais. Para fechar, vejamos a questão de prova cobrada, em maio de 2026, na prova do Ministério Público do Rio de Janeiro para o cargo de promotor, a respeito dos temas estudados nesse tópico:

No curso de investigação sobre organização criminosa voltada à prática de fraudes bancárias, a autoridade policial apreendeu diversos dispositivos eletrônicos como *notebooks* e *smartphones* na residência de um dos investigados, sem a imediata lavratura detalhada dos procedimentos de acondicionamento e lacração.

Posteriormente, já na unidade policial, um dos aparelhos foi acessado por um agente policial não perito, antes da realização de espelhamento forense, sendo extraídas conversas de aplicativo de mensagens que indicariam a participação do investigado nos delitos. A perícia oficial, realizada dias depois, reconheceu que não houve preservação integral dos metadados originais, tampouco registro completo dos elos da cadeia de custódia digital, embora tenha conseguido recuperar parte relevante das conversas, que coincidem com aquelas inicialmente visualizadas pelo agente policial.

Com base nessas informações, a autoridade policial obteve, mediante autorização judicial, dados junto à instituição financeira, que corroboraram as transações ilícitas. Na sentença, o Juiz reconheceu falhas na cadeia de custódia dos dispositivos, mas admitiu as provas obtidas junto à instituição financeira, condenando o réu.

Diante desse cenário, é correto afirmar que

A a manipulação prévia do dispositivo por agente não perito e a ausência de preservação integral dos metadados não representaram quebra na cadeia de custódia e poderiam ser utilizadas pelo Juiz.

B a ausência de cadeia de custódia formalmente documentada não tornou inadmissível a prova digital, que poderia ter sido utilizada pelo Juiz, pois não se constatou violação direta ao devido processo legal.

C as falhas na preservação dos vestígios digitais implicam o reconhecimento de ilicitude probatória em razão da quebra da cadeia de custódia, contaminando as demais provas obtidas junto à instituição financeira.

D a manipulação prévia do dispositivo por agente não perito no acesso inicial ao dispositivo configura nulidade relativa, sanável pela posterior perícia oficial, que convalidou os elementos informacionais obtidos.

E as falhas na preservação dos vestígios digitais podem comprometer a confiabilidade da prova, contudo, as provas obtidas junto à instituição financeira devem ser admitidas, pois configuram fonte independente.

Por fim, só para se ter ideia da relevância do tema, veja a questão discursiva que foi cobrada na prova discursiva do Ministério Público do Rio de Janeiro aplicada em 12/07/2026:

QUESTÃO (VALOR 0,50): O que é a função hash e qual a sua relevância para a cadeia de custódia nas provas digitais?

INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

Conforme observou-se anteriormente, dizer que **a imputação fática está provada é entender que os elementos apresentados possibilitam superar a dúvida razoável do julgador e vencer a presunção de inocência no sentido de que os fatos que fundamentam essa imputação ocorreram da forma descrita pela acusação nos casos de decisões condenatórias.**

Para a obtenção dessa verdade processual ou “verdade possível”, o procedimento penal conta com uma fase própria para a produção probatória: a instrução criminal.

FREDERICO MARQUES trata da **instrução probatória** como “o conjunto de atos processuais que têm por objeto recolher as provas com que deve ser decidido o litígio”. É na instrução que as partes procuram fixar os dados do processo, apreciar o seu valor e formular em torno dos mesmos as necessárias críticas, oferecendo material lógico ao juiz, para a construção da sentença. É na fase processual em que se praticam os atos probatórios e se produzem as alegações conclusivas (Marques, 1997).

A informação relevante nesse tópico é a seguinte: apesar de o processo contar com fase própria para a produção probatória, fato que é esses elementos são produzidos durante toda a marcha processual. Nesse sentido, valemo-nos, mais uma vez, das relevantes lições de Frederico Marques:

Cumprе assinalar, porém, que, se a instrução probatória é a fase procedimental específica para a produção de provas, atos instrutórios já se praticam desde a fase postulatória da instância e até mesmo nos atos preparatórios da investigação policial ou de outra informatio delicti que tenha servido de base à acusação. Assim é que a juntada de documentos, por exemplo, com a denúncia, constitui ato de instrução probatória. Por outro lado, as perícias efetuadas na investigação preparatória têm quase sempre, caráter de ato probatório definitivo. Além do mais, determina o artigo 12 que o “inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra”. Pelo próprio teor do texto, verifica-se que a função dos autos dessa investigação preparatória está em servir de fundamento a opinio delicti que legitima a propositura da ação penal. Mas a verdade é que o inquérito, embora não possa, com suas provas, constituir-se como base da sentença definitiva, contém, no entanto, elementos indiciários e circunstanciais complementares que podem, esclarecer, reforçar ou consolidar elementos de convicção colhidos na fase instrutória da instância penal. Assim sendo, o inquérito que acompanha a denúncia é, sob certo aspecto, uma peça de instrução e que constitui, por isso, elemento probatório colhido fora da fase instrutória (Marques, 1997).

STANDARDS PROBATÓRIOS.

Considerando os ensinamentos prestados por Gustavo Badaró, o qual correlaciona verdade e prova, trata de diversos momentos da atividade processual decisória:

- Momento da descoberta.

- Momento da instrução.
- Momento da valoração.
- Momento da decisão.
- Momento da justificação.

Partindo dessa premissa, o referido autor diferencia o momento da valoração do momento da decisão:

*A atividade valorativa tem por objeto os meios de prova, que deverão ser confrontados e valorados segundo regras lógicas e racionais. A valoração leva à decisão sobre a veracidade ou não de uma determinada afirmação sobre os fatos. Todavia, os momentos de valoração e decisão não se confundem, e, mais relevante do que isso, são regidos por estatutos distintos. **O contexto da valoração é eminentemente racional. Em um sistema de persuasão racional, as regras jurídicas não devem ter influência sobre como valorar os meios de provas.***

*Questão diversa diz respeito ao critério de decisão. **Cabe ao legislador, a partir de um determinado valor que deseje tutelar, estabelecer critérios de decisão que poderão variar, por exemplo, segundo o bem jurídico em jogo, ou a natureza do processo.** Esse é o campo dos critérios de decisão, ou qual o grau de convencimento que se exige do julgador para poder decidir que um fato está provado. O tema dos “critérios de decisão”, também denominados “standards probatórios” ou “modelos de constatação”, tem sido muito pouco explorado pela doutrina processual penal brasileira, que geralmente se limita a apreciar a questão sob o enfoque do *in dubio pro reo*, mas não dos diversos graus que se podem exigir do julgador para que considere um fato “provado” ou mesmo para que se tenha como satisfeito um requisito legal de mera probabilidade, e não de “certeza”.*

Relata que diversos *standards* podem ser adotados:

- simples “**preponderância de provas**” (preponderance evidence), que significa a mera probabilidade de um fato ter ocorrido;
- “**prova clara e convincente**” (clear and convincing evidence), que pode ser identificada como uma probabilidade elevada;
- “**prova além da dúvida razoável**” (beyond a reasonable doubt), como uma probabilidade elevadíssima, que muito se aproxima da certeza. Gustavo Badaró trabalhou com o método indutivo, também chamado de probabilidade indutiva, probabilidade lógica ou baconiana.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA FUNDAMENTAR O VEREDITO. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO E DEPOIMENTOS INDIRETOS. INSUFICIÊNCIA. IMPRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

*3. No caso ora em exame, a condenação do réu pelos jurados foi amparada, tão somente, em uma oitiva colhida no inquérito policial e em **provas indiretas** das testemunhas sigilosas, cujos depoimentos não foram corroborados pelas duas fontes originárias indicadas. Uma delas nem sequer foi arrolada como testemunha e a outra era o*

réu, que exerceu o seu direito ao silêncio nas fases inquisitorial e judicial. Assim, não havia prova idônea e suficiente para fundamentar a decisão dos jurados, razão pela qual foi violado o art. 593, III, "d", do CPP. Não havia substrato mínimo nem sequer para lastrear a pronúncia do acusado, o que conduz à sua despronúncia ex officio.

4. Embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem que haja sido atingido um standard probatório suficiente, que se situa "entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro standard que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado" (REsp n. 2.091.647/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 3/10/2023).

AgRg no AREsp 2428788 / PR AGRADO REGIMENTAL NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL 2023/0284248-4.

O tema foi enfrentado na prova do Ministério Público do Estado do Goiás no ano de 2019, vejamos a questão adaptada:

René Floriot, famoso advogado criminalista francês, dizia que *“mesmo nos casos mais simples é muito comum existir um elemento misterioso que ninguém conseguiu elucidar”*. Francesco Carnelutti, ilustre processualista italiano, em clássica afirmação, asseverava que *“a verdade está no todo, não na parte; e o todo é demais para nós”*.

Sobre a temática da prova e da busca da verdade no processo penal, julgue os itens a seguir: ⁵

() Consoante magistério doutrinário de Luigi Ferrajoli, a verdade certa, objetiva ou absoluta representa a expressão de um ideal inalcançável. Sendo assim, a crença no sentido de que se pode alcançar uma verdade absolutamente certa é, na realidade, uma ingenuidade epistemológica, afinal, a verdade que se obtém no processo é uma verdade aproximativa.

() Segundo o *standard* de prova *beyond a reasonable doubt*, a quantidade de prova (*quantum of proof*) exigida no processo penal para fins de condenação é aquela produzida além da dúvida razoável. Esse *standard* probatório, oriundo do Direito Anglo-Saxão, ainda não foi utilizado pelo STF em seus julgados, muito embora haja doutrina no sentido de sua compatibilidade com o Direito Processual Penal brasileiro.

O tema foi objeto na prova do MPDF/2025 para o cargo de promotor, vejamos a questão adaptada:

⁵ Gabarito: C, E.

Quanto à atuação do Ministério Público em matéria probatória no processo coletivo, julgue o item a seguir:

Questão adaptada () Standards de prova dizem respeito ao quanto de prova para se considerar provado, atuam na fase inicial da valoração probatória determinando o umbral a ser ultrapassado; enquanto ônus da prova é utilizado como regra de atividade para atribuir quem deve se encarregar da produção e como regra de julgamento para sancionar quem poderia ter provado e não provou.⁶

Ainda a respeito do tema, vejamos a interessante questão cobrada na prova da Defensoria Pública do Estado da Bahia em abril de 2026, observe: ⁷

O Professor Gustavo Badaró, em festejado livro, escreve inicialmente que *"afastada a possibilidade de se atingir um conhecimento racional absoluto sobre a verdade dos enunciados fáticos, também no campo da valoração da prova tem se entendido que tal se dá por meio de um juízo de probabilidade"*. Após analisar alguns modelos de probabilidade de valoração da prova, conclui que *"o melhor método para a valoração da prova judicial é aquele em que, com base nos elementos disponíveis, o juiz valora o grau de suporte que o meio de prova dá para uma hipótese sobre um evento particular e desconhecido. A força da inferência vai aumentando à medida que a hipótese vai superando os controles probatórios elaborados para falseá-la, o que aumenta sua probabilidade"* (**Epistemologia judiciária e prova penal**. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 225).

O autor está a falar do método probabilístico de valoração de prova denominado probabilidade

- A dedutiva.
- B subjetiva.
- C estatística.
- D objetiva.
- E indutiva.

CLASSIFICAÇÃO DAS PROVAS.

Nesse tópico, tentaremos reunir as diversas classificações operacionalizadas no âmbito da doutrina:

CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO OBJETO.

Essa classificação busca realizar a classificação da prova quanto ao fato que deve ser demonstrado.

- **Provas Diretas** → São aquelas que sozinhas, por meio de uma **única operação inferencial**, permitem conhecer do fato objeto de prova. Ex. testemunho de uma pessoa que presenciou a prática do homicídio.

Muito Cuidado:

⁶ Gabarito: C.

⁷ Gabarito: E.

A prova testemunhal pode ser classificada como direta ou indireta, a depender do fenômeno presenciado pela testemunha.

Vejamos interessante questão de prova cobrada pela FUNDATEC em 2025:

() A prova testemunhal é considerada prova direta, pois as testemunhas presenciam o fato criminoso e o reproduzem fielmente em juízo.⁸

- **Provas Indiretas →** São aquelas que, provado um fato, permite-se, **por meio de um raciocínio dedutivo, lógico, chegar-se a outra conclusão**. Ex. Alibi.

Renato Brasileiro trata a respeito das provas indiretas:

Outro exemplo de prova indireta diz respeito ao alibi. Etimologicamente, a palavra alibi significa a "defesa que o réu apresenta quando pretende provar que não poderia ter cometido o crime por, p. ex, encontrar-se em local diverso daquele em que o crime de que o acusam foi praticado". Supondo, então, que o suspeito consiga comprovar que estava em outro local no exato momento em que o crime foi praticado, conclui-se não ter sido ele o executor do crime (Lima, 2018).

O tema “prova indireta” é comum em provas de concurso público, vejamos como o tema já foi objeto de prova:

Promotor de justiça / GO⁹ () Quanto ao objeto, as provas podem ser diretas ou indiretas. As provas diretas referem-se imediatamente ao objeto a ser provado (fato probando). Já a prova indireta demonstra a existência de outro fato, que se liga ao fato a ser provado por uma construção lógica. Assim, é possível afirmar que a prova indiciária é sempre indireta.

Defensoria Pública do DF () De acordo com o direito processual penal e com o Código de Processo Penal (CPP), julgue os itens que se seguem.

() ¹⁰A prova indiciária é indireta por excelência, se se considerar necessária uma construção lógica para que se chegue a uma circunstância

CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO VALOR.

Vejamos a classificação:

- Prova plena → Classificação tradicional utilizada para designar a prova ou o conjunto probatório que alcança grau de confirmação suficiente para a decisão a ser proferida. Tradicionalmente, afirma-se que a prova plena permite um “juízo de certeza”. À luz da moderna epistemologia da prova, contudo, é mais adequado falar em suficiência probatória segundo o standard aplicável, pois a decisão judicial não depende de certeza absoluta, mas de um grau racionalmente suficiente de confirmação da hipótese fática.

⁸ Gabarito: E

⁹ Gabarito: C.

¹⁰ Gabarito: C.

- Prova não plena ou semiplena → É aquela que proporciona grau de confirmação inferior ao necessário para determinada decisão de mérito, embora possa ser suficiente para decisões que exijam standard probatório menos elevado, como certos juízos cautelares ou de admissibilidade. Sua insuficiência é, portanto, relativa ao standard exigido para a decisão concreta, e não uma característica absoluta ou um valor previamente fixado do meio de prova.

Atenção: prova não plena não se confunde com prova indireta ou indiciária. A prova indiciária prevista no art. 239 do CPP pode, quando formada por indícios graves, convergentes e racionalmente articulados, atingir grau de confirmação suficiente inclusive para uma condenação

Renato Brasileiro apresenta alguns exemplos a respeito das provas não plenas:

- **Indício.**
- **Fundada suspeita.** (Art. 240, §2º, CPP.)
- **Segundo Tornaghi**, a prova *prima facie*. Para exemplificar: se uma pessoa indefesa, à noite, dentro da própria casa, mata um ladrão contumaz, que arrombou uma janela, *prima facie*, isto é, à primeira vista, tudo convence de que o homicídio foi praticado em legítima defesa”.

A pergunta a ser respondida, nesse momento, é a seguinte:

Os indícios podem ser utilizados na formação da convicção do juiz? É possível realizar a condenação com base exclusivamente em indícios?

A resposta a esse questionamento parte da premissa do que é indício. A doutrina, em algumas vezes, se refere a indícios como prova indireta e, em outras, como prova semiplena.

Renato Brasileiro nos ensina que, considerando o indício como prova indireta, em tese seria possível a condenação com base em indícios (*termo no plural*) desde que reunidas algumas condições:

- a) os **indícios devem ser plurais** (somente excepcionalmente um único indício será suficiente, desde que esteja revestido de um potencial incriminador singular);
- b) devem **estar estreitamente relacionados entre si**;
- c) devem ser **concomitantes**, ou seja, **univocamente incriminadores** - não valem as meras conjecturas ou suspeitas, pois não é possível construir certezas sobre simples probabilidades;
- d) existência de **razões dedutivas** - entre os indícios provados e os fatos que se inferem destes deve existir um enlace preciso, direto, coerente, lógico e racional segundo as regras do critério humano.

Essa é a aceção do indício no âmbito do artigo 239, CPP, vejamos:

Art. 239. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.

Esse tema foi objeto de cobrança na prova para Perito Criminal do Estado do Rio Grande do Sul no ano de 2025, vejamos:

() O sistema de valoração adotado pelo Código de Processo Penal impede que o juiz condene com base em prova indireta (indiciária), pois esta não possui força suficiente para afastar a dúvida razoável.¹¹

Por outro lado, se considerarmos indício como prova semiplena, aquela que não outorga um juízo de certeza, a resposta seria negativa. Nesse sentido, Renato Brasileiro relata que

(...) esta acepção, a expressão "indício" refere-se a uma cognição vertical (quanto à profundidade) não exauriente, ou seja, uma cognição sumária, não profunda, em sentido oposto à necessária completude da cognição, no plano vertical, para a prolação de uma sentença condenatória.

CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO SUJEITO.

Quando a esse tópico, as provas podem ser classificadas em provas reais ou pessoais.

- **Provas reais** → São aquelas que **não advém diretamente da pessoa**, por outro lado, possibilitam a influência na cognição a partir de objetos, a título de exemplo, a arma empregada para a prática do crime.
- **Provas pessoais** → São aquelas que decorrem diretamente de **impressões pessoais**. Ex. interrogatório, testemunho, prova pericial.

CLASSIFICAÇÃO COM RELAÇÃO AOS FATOS QUE SE PRETENDE DEMONSTRAR.

Nesse sentido, as provas podem ser classificadas em positivas ou negativas.

Provas Positivas: São provas que visam **demonstrar a existência de um fato**.

Provas Negativas: Provas que visam **demonstrar a inexistência de um fato ou a existência de um novo fato que infirme a existência de um fato anterior** (prova negativa indireta).

CLASSIFICAÇÃO QUANTO À PREVISÃO LEGAL.

Nessa versão de nosso curso, preferimos adotar a posição adotada por Leonardo Barreto em sua obra, contudo alertamos que o tema se mostra divergente a depender da doutrina adotada para estudo.

Quanto à previsão legal, as provas podem ser classificadas em nominadas ou inominadas.

- **Provas nominadas:** Trata-se de meio de prova previsto expressamente pela legislação processual penal, indicando o seu nome jurídico, podendo ser estabelecido ou não o procedimento destinado a sua produção. Nesse sentido, fala-se em prova nominadas típicas ou atípicas.
 - **Prova típica:** É aquela que é aquela que, além de nominalmente prevista em lei, conta com previsão expressa a respeito da forma pela qual deve ser produzida. Ex. prova testemunhal, além de estar expressamente prevista na norma, o CPP prevê o procedimento para a sua produção.

¹¹ Gabarito: E.

- **Prova atípica:** É aquela que conta com previsão legal, mas não possui procedimento legalmente delineado para a sua produção. Ex, reprodução simulada dos fatos.

Muito cuidado com o posicionamento apresentado por Renato Brasileiro, citando as valiosas lições do professor Guilherme Madeira:

*De acordo com a doutrina, há duas posições acerca do conceito de provas atípicas: a) **posição restritiva:** a ideia da atipicidade probatória é vista de maneira intimamente ligada à ausência de previsão legal da fonte de prova que se quer utilizada no processo. Assim, a atipicidade probatória guarda estreita ligação com a ausência de previsão legal da fonte de prova, confundindo-se os conceitos de prova atípica e de prova inominada; b) **posição ampliativa:** uma prova é atípica em duas situações: b.1) quando ela estiver prevista no ordenamento, mas não haja procedimento probatório; b.2) quando nem ela nem seu procedimento probatório estiverem previstos em lei*

Vejamos interessante questão cobrada na prova do MPSC/2024: ¹²

Ano: 2024 **Banca:** [Instituto Consulplan](#) **Órgão:** [MPE-SC](#) **Prova:** [Instituto Consulplan - 2024 - MPE-SC - Promotor de Justiça Substituto - P1 - Fase Matutina](#)

() O reconhecimento pessoal é espécie de prova nominada, típica e irrepetível. Nominada porque é prevista expressamente na lei e típica porque seu procedimento probatório também está previsto em ato normativo. A despeito de ser prova irrepetível, não é possível ao juiz fundamentar a condenação exclusivamente no ato de reconhecimento, mesmo quando a vítima do roubo tenha manifestado grau máximo de confiança quanto ao reconhecimento do suspeito.

Ainda a respeito da tipicidade e atipicidade da prova, vejamos questão interessante cobrada no ano de 2026 na prova do MPAL para o cargo de Analista:

Ano: 2026 **Banca:** [FCC](#) **Órgão:** [MPE-AL](#) **Prova:** [FCC - 2026 - MPE-AL - Analista de Ministério Público - Área Jurídica](#)

Questão Adaptada () Thiago responde a ação penal em cujo bojo foi apresentado laudo pericial tendo por objeto aparelho de telefonia celular de sua titularidade. Nos termos do Código de Processo Penal, pretendendo o Ministério Público ouvir o perito em audiência. O perito poderá ser ouvido em audiência apenas se houver concordância da parte contrária, por não ser o perito testemunha e se tratar de prova atípica sua ouvida em juízo. ¹³

Prova inominada → Considerando o princípio da liberdade probatória, a prova inominada é aquela que, a despeito de não ter previsão no ordenamento jurídico, não é vedada pelo ordenamento ou pelos bons costumes. Ex. certidões emitidas pelos oficiais de justiça, não se tratam de provas testemunhais, mas meras informações a respeito de determinado fato.

¹² Gabarito: C.

¹³ Gabarito: E.

CLASSIFICAÇÃO QUANTO À FINALIDADE.

- **Prova anômala** → É aquela que é ocorre um desvio de finalidade no uso da prova. Consiste no uso de um meio de prova com previsão no mundo jurídico em substituição a outro meio de prova também previsto. **Trata-se de severo vício de finalidade com a utilização de um meio de prova previsto e válido contudo para finalidade distinta e, portanto, imprópria para aquele fim.**

Ex. ao invés de expedir a carta precatória para a oitiva de testemunha que se encontra em outro Estado, adota-se certidão do oficial de justiça que entra em contato com a vítima e toma o seu depoimento. Trata-se de modalidade que ostenta um vício mais grave do que a prova irritual.

- **Prova irritual** → É a prova típica que é produzida em desconformidade com o modelo legalmente estabelecido. Ex. oitiva da vítima de um crime sexual por escrito. Ex. Reconhecimento fotográfico. ¹⁴Trata-se de prova ilegítima que não observa o procedimento definido para a sua produção. A validade da prova irá depender da gravidade do vício ostentado.

A esse respeito, Guilherme Madeira pontua:

(...) a prova anômala é produzida segundo o modelo legal. Seu problema consiste em que o modelo legal utilizado não é o adequado para o caso, não é o que o caso requer. Já a prova irritual não é produzida segundo o modelo legal. Em verdade, utiliza-se o meio adequado, mas sem a observância dos elementos típicos previstos em lei. Ou seja, na prova anômala segue-se o procedimento previsto em lei, mas não o procedimento previsto para aquele meio de prova. Na prova irritual segue-se o procedimento previsto para o meio de prova, mas sem a observância do modelo previsto em lei

A respeito da prova atípica, o STJ entendeu que a “autópsia psicológica” constitui prova atípica admissível no processo penal, cabendo ao magistrado controlar a sua utilização no caso concreto:

Não vigora no campo penal um sistema rígido de taxatividade dos meios de prova, sendo admitida a produção de provas não disciplinadas em lei, desde que obedecidas determinadas restrições. A análise sobre a validade da prova atípica perpassa, pois, pelo campo epistemológico.

Não existe um dispositivo específico que trate sobre as provas atípicas no CPP. No entanto, é possível utilizar, por analogia - como autoriza o art. 3º do CPP -, o art. 369 do CPC.

Significa dizer, em última análise, que o rol de provas previsto no Título VII do CPP é exemplificativo.

¹⁴ chrome-

extension://efaidnbmnnnibpajpcglclefindmkaj/https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ATC?CodOrgaoJgdr=&SeqCgrmaSessao=&dt=&formato=PDF&nreg=&salvar=false&seq=116061726&tipo=0

Assim, o simples fato de não constar do catálogo legal relacionado às “provas em espécie” não configura razão suficiente para que a perícia ora impugnada seja considerada inadmissível.

A “autópsia psicológica”, raras vezes utilizada na praxis forense brasileira, consiste em exame retrospectivo que busca compreender os aspectos psicológicos envolvidos em mortes não esclarecidas.

A “autópsia psicológica” não constitui prova ilícita ou ilegítima, razão pela qual não deverá ser desentranhada. Além disso, é admissível, por ser possível ser refutada - seja porque há indicação das fontes originárias dos depoimentos, preservando a cadeia de custódia, seja porque os assistentes técnicos puderam contestar sua cientificidade no curso do processo.

No entanto, trata-se de prova ainda não padronizada pela comunidade científica e erigida, inegavelmente, em aspectos subjetivos.

Assim, incumbirá aos jurados, juízes naturais da causa, realizar o cauteloso cotejo do referido laudo com o restante do acervo probatório acostado aos autos. STJ. 6ª Turma. HC 740431-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 13/9/2022 (Info Especial 10).

A respeito da autópsia psicológica, vejamos interessante explicação a respeito do assunto¹⁵:

“A autópsia psicológica pode ser definida como um tipo de avaliação psicológica realizada retrospectivamente através de uma investigação imparcial, que objetiva compreender os aspectos psicológicos de uma determinada morte. Busca-se compreender o que havia na mente do indivíduo. Ela visa reconstruir a vida psicológica de um indivíduo, analisando o seu estilo de vida, a personalidade, a saúde mental, os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos precedentes a morte, a fim de alcançar um maior entendimento sobre as circunstâncias que contribuíram para o fato. Além disso, a autópsia psicológica pode auxiliar no esclarecimento do modo da morte, que pode ser natural, acidental, por suicídio ou homicídio.”

PROVA EMPRESTADA.

A prova emprestada funciona como clara expressão do **princípio da economia processual**. Trata daquelas situações em que determinada prova produzida em determinado processo é transportada para outro com a aptidão de influenciar o julgador em sua decisão.

¹⁵ (Clark & Horton-Deustch, 1992; Gavin e Rogers, 2006; Isometsä, 2001; Jacobs e Klein-Benheim, 1995; Shneidman, 1992, 1994, 2004).” (MIRANDA, Tatiane Gouveia de. Autópsia psicológica: compreendendo casos de suicídio e o impacto da perda. Dissertação (mestrado), Universidade de Brasília. Brasília, 2014. Disponível em: https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/16392/1/2014_TatianeGouveiaMiranda.pdf

A professora ADA PELLEGRINI GRINOVER, em artigo publicado na Revista Brasileira de Ciências Criminais, ano 1, no 4, out./dez. 1993, p. 60, conceitua-a como “aquela que é produzida num processo para nele gerar efeitos, sendo depois transportada documentalmente para outro, visando a gerar efeitos em processo distinto”.

Conforme as lições de Paulo Rangel, trata-se de **meio de prova inominada, que, quanto à forma, será sempre documental.**

O tema foi cobrado na prova do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para o cargo de técnico judiciário, vejamos:

Ano: 2026 Banca: FGV Órgão: TJ-RJ Prova: FGV - 2026 - TJ-RJ - Técnico de Atividade Judiciária - Sem Especialidade ¹⁶

Em procedimento no Tribunal do Júri em razão da imputação da prática do crime de homicídio cometido por Fausto, o Ministério Público requereu, durante a instrução preliminar em juízo, observados o contraditório, o devido processo legal e as regras de competência, que fosse juntado aos autos depoimento do mesmo acusado, que se encontrava em outro processo anterior, no qual Fausto também era réu e que se processou naquele mesmo juízo.

Relativamente à possibilidade, ou não, de se trasladar o referido depoimento de Fausto para o processo atual e neste ser utilizado, é correto afirmar, segundo a doutrina, que sua utilização:

- A será possível, em razão do princípio da comunhão das provas no processo penal;
- B será possível, em razão da viabilidade de se utilizar a prova emprestada no processo penal;
- C não será possível, por violação do princípio da fiabilidade das provas;
- D será possível, em razão do princípio da íntima convicção motivada do juiz;
- E não será possível, em razão da ilicitude probatória por derivação.

O tema também foi objeto de cobrança na prova de Juiz de Direito do Estado da Bahia no ano de 2026, vejamos o questionamento: ¹⁷

Ano: 2026 Banca: FGV Órgão: TJ-BA Prova: FGV - 2026 - TJ-BA - Juiz Substituto

Mateus foi denunciado em razão da prática do crime de latrocínio contra Artur. Durante a instrução criminal, o Ministério Público juntou aos autos cópias de trechos de interceptações telefônicas obtidas sem autorização judicial, que foram produzidas em outro processo, no qual Mateus também fora acusado. Contudo, o Ministério Público não requisitou que viesse aos autos o laudo de confronto balístico realizado.

Diante desse cenário, o juiz, com vistas a dirimir dúvida sobre ponto relevante:

- A poderá requisitar a vinda aos autos do laudo faltante e deverá determinar que a prova juntada pelo Ministério Público seja desentranhada dos autos em razão de sua ilicitude;
- B poderá requisitar a vinda aos autos do laudo faltante e deverá admitir a prova emprestada juntada pelo Ministério Público, purgando a sua ilicitude derivada diante da fonte independente;
- C não poderá requisitar a vinda aos autos do laudo faltante e deverá determinar que a prova juntada pelo Ministério Público seja desentranhada dos autos em razão de sua ilicitude derivada;

¹⁶ Gabarito: A.

¹⁷ Gabarito: A.

D poderá requisitar a vinda aos autos do laudo faltante e deverá admitir a prova emprestada juntada pelo Ministério Público, diante do princípio da busca da verdade real no processo penal;

E não poderá requisitar a vinda aos autos do laudo faltante e deverá admitir a prova emprestada juntada pelo Ministério Público, diante do princípio da busca da verdade real no processo penal.

A doutrina majoritária posiciona-se favoravelmente à possibilidade de provas emprestadas, exigindo-se basicamente dois requisitos:

- **Similaridade de partes*** ou, ao menos, a participação da parte contra a qual a prova será utilizada.
- Similaridade de fatos a serem provados.
- **Exigência de contraditório.**
- Observância das formalidades no que concerne à produção da prova.

Não tem prevalecido no cenário jurisprudencial brasileiro a exigência de similaridade de partes, inclusive, esse tema foi objeto de cobrança na prova do Ministério Público do Paraná no ano de 2025, vejamos a questão adaptada:

() É admissível a utilização de prova emprestada, desde que seja garantido o contraditório, mesmo que diferido, no processo receptor, não sendo necessária a identidade absoluta de partes.¹⁸

Norberto Avena milita nesse sentido, ocasião em que relata que, “como prova emprestada, compreende-se aquela que, produzida originariamente em um determinado processo, vem a ser apresentada, documentalmente, em outro. Para que seja admissível, é preciso que ambos os feitos envolvam as mesmas partes e que, na respectiva produção, tenha sido observado o contraditório. Satisfeitas estas duas condições, terá a prova emprestada o mesmo valor das demais provas realizadas dentro do processo.”

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência do STJ:

STJ - Súmula 591: É permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa.

Posteriormente, foi fixada a Tese no tema 1238 – Repercussão Geral: “São inadmissíveis, em processos administrativos de qualquer espécie, provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário”. ARE 1316369 RG, julgado em 08/12/2022.

Posicionamento correlato foi apresentado pelo STJ no final do ano de 2025, vejamos:

É inadmissível a condenação, em processo administrativo disciplinar, amparada em prova penal emprestada considerada ilícita, ainda que essa ilicitude tenha sido declarada posteriormente à conclusão do PAD.

¹⁸ Gabarito: C

[AgRg na Rcl 47.632-DF](#), Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Rel. para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, por maioria, julgado em 10/12/2025, DJEN 23/12/2025.

Em outro recente posicionamento datado de 2026, decidiu o STJ:

A extinção, sem resolução de mérito, da ação cível de produção antecipada de provas por inadequação da via eleita não implica, por si só, inutilização ou invalidade das provas, se ausente declaração de ilicitude, podendo ser legitimamente compartilhadas para fins penais, observados os requisitos legais e constitucionais.

[AgRg no RMS 77.635-SP](#), Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Rel. para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, por maioria, julgado em 12/5/2026, DJEN 25/5/2026.

O tema foi objeto de cobrança na prova discursiva para o Cargo de Promotor de Justiça do Estado do Paraná, vejamos o questionamento:

Uma vez regularmente autorizada pelo juiz competente a realização de interceptação telefônica para o fim de investigação criminal nos termos da Lei nº 9.296/96, é cabível que o mesmo juiz autorize o compartilhamento dos elementos probatórios obtidos, a título de prova emprestada, com processo administrativo disciplinar instaurado contra a mesma pessoa investigada? (0,5 ponto)

Muito cuidado: Em relação à similaridade de partes, nos parece que ambos os tribunais superiores têm flexibilizado essa exigência, vejamos alguns precedentes:

INQUÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA (Código Penal art. 317, § 1º). DENÚNCIA APTA. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. FATOS TÍPICOS EM TESE DESCRITOS. DENÚNCIA RECEBIDA. 1. A utilização de prova emprestada legalmente produzida em outro processo de natureza criminal não ofende os princípios constitucionais do processo. 2. O amplo acesso à totalidade dos áudios captados realiza o princípio da ampla defesa. De posse da totalidade das escutas, o investigado não possui direito subjetivo à transcrição, pela Justiça, de todas as conversas interceptadas. Não há ofensa ao princípio da ampla defesa. Precedentes desta Corte. [...] (Inq 4023, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 23/08/2016).

No âmbito do STJ é ainda mais evidente esse posicionamento:

[...] "Conforme entendimento desta Corte Superior, uma vez garantido às partes do processo o contraditório e ampla defesa por meio de manifestação quanto ao teor da prova emprestada, como no caso dos autos, não há vedação para sua utilização, ainda que não exista identidade de partes com relação ao processo na qual foi produzida" (AgRg no AREsp 1.104.676/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, j. em 11/12/2018) (HC 446.296/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 30/4/2019). (AgRg no AgRg no REsp 1824834/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020).

No ano de 2024, a 6ª Turma do STJ teve nova oportunidade de se manifestar sobre a validade da prova emprestada, mesmo diante a ausência da similaridade de partes, ocasião em

que também asseverou que não é possível a transferência da discussão de um processo para o outro a respeito da quebra da cadeia de custódia.

*AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. **PROVA EMPRESTADA**. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DA LEGALIDADE NO PROCESSO DE ORIGEM. INVIABILIDADE. INDEVIDA INGERÊNCIA EM FORO DISTINTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.*

1. "Para a observância do devido processo legal e do contraditório, não é necessário que haja absoluta identidade de partes entre o processo de que se empresta a prova e o processo para o qual esta é emprestada, pois o contraditório sobre a prova (contraditório postergado ou diferido) satisfaz esses princípios. A circunstância de o agravante não haver participado originariamente da elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo em que ele figura como acusa." (AgRg no RHC 140.259/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe 9/4/2021,)

2. O compartilhamento de provas não importa no traslado da discussão de toda a cadeia de custódia ao processo receptor, sob pena de indevida ingerência entre juízos diversos, situação que será resolvida em procedimentos próprios, e.g., conflito de competência ou aplicação de institutos como o da continência ou conexão, e não pela presente via, mediante recurso ordinário em habeas corpus, instrumento de estreitos limites cognitivos cujo objetivo é o de garantir o direito de locomoção constrangido ilegalmente ou em vias de ser restringido de forma ilícita.

AgRg no RHC 169223 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2022/0248352-2; Relator Min. Saldanha Palheiros; 6ª Turma, julgado em 12/08/2024.

Paulo Rangel, em sentido minoritário, aponta requisitos para que seja lícita a prova emprestada no âmbito processual:

- Similaridade de partes.
- Observância das formalidades legais o processo originário.
- O fato a ser provado deve ser o mesmo.
- Pleno exercício do contraditório no processo do qual a prova será transferida.

COMPARTILHAMENTO DE DADOS FISCAIS E BANCÁRIOS.

O STF, em repercussão geral, pacificou o tema e entendeu que é possível o compartilhamento com os órgãos encarregados de poder de investigação de dados bancários e fiscais, obtidos pela Receita Federal e pela UIF (COAF).

É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil (RFB), que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional.

2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. Essa é a tese do Tema 990 da Repercussão Geral fixada, por maioria, pelo Plenário (Informativos 960 e 961). Vencido o ministro Marco Aurélio, que não referendou a tese. (RE 1055941/SP, rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 4.12.2019).

O tema 990-STF tem sido objeto de cobrança em concursos relevantes, vejamos:

Ano: 2024 Banca: [VUNESP](#) Órgão: [MPE-RO](#) Prova: [VUNESP - 2024 - MPE-RO - Promotor de Justiça Substituto](#)

Haja vista o envio de relatórios de inteligências financeiras pelo COAF, no exercício de suas atribuições, reportando ao Ministério Público movimentações financeiras suspeitas de X, funcionário público, e de seus familiares, é requisitada a instauração de Inquérito Policial, o que é atendido pela autoridade competente. (...) ¹⁹

Questão Adaptada () O procedimento, como um todo, estaria maculado por vício originário (ilicitude de prova), sendo vedado ao órgão de fiscalização (COAF) enviar ao Ministério Público informações bancárias sem autorização judicial.

O tema também foi cobrado na prova de Juiz do Estado de Sergipe, vejamos a questão:

Ano: 2025 Banca: [FGV](#) Órgão: [TJ-SE](#) Prova: [FGV - 2025 - TJ-SE - Juiz Substituto](#) ²⁰

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) enviou, espontaneamente, ao Ministério Público um Relatório de Inteligência Financeira (RIF), segundo o qual o casal Ferdinando e Imelda e seis sociedades empresárias das quais ambos são sócios apresentam movimentação financeira atípica. O promotor de justiça instaurou notícia de fato, no bojo da qual diligência de campo revelou que não há qualquer atividade econômica em andamento nos endereços apontados como sedes das seis sociedades empresárias. Além disso, pesquisas em fontes abertas, especialmente redes sociais, mostraram que o casal Ferdinando e Imelda ostenta elevado padrão de vida, com carros importados, viagens de luxo e jantares em restaurantes caros. Em diversas postagens, o casal aparece na companhia de Alfredo, integrante de família conhecida na Comarca pelo envolvimento com a contravenção penal do jogo do bicho. Há, no mesmo órgão ministerial, um Procedimento Investigatório Criminal (PIC) em que Alfredo é investigado, já presentes robustos elementos de convicção no sentido da prática da referida contravenção. O promotor de justiça reuniu a notícia de fato ao PIC e aditou a portaria de instauração para incluir o casal e novo objeto, vale dizer, o crime de lavagem de dinheiro. Prosseguindo as diligências, solicitou o Ministério Público ao COAF, via sistema institucional, informações financeiras acerca de Alfredo. A resposta do COAF foi positiva, e o órgão remeteu ao Ministério Público um RIF que aponta movimentações financeiras atípicas por parte de Alfredo.

O promotor de justiça requereu judicialmente a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Ferdinando e Imelda, das sociedades empresárias titularizadas por ambos e de Alfredo. Com base na Lei nº 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Capitais) e no entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, o magistrado deverá:

A deferir integralmente a pretensão do Ministério Público;

B indeferir o pedido de quebra de sigilo bancário, porque o crime de lavagem de dinheiro admite, como antecedente, crime, mas não contravenção penal;

¹⁹ Gabarito: Errado.

²⁰ Gabarito: A

C indeferir o pedido de quebra de sigilo bancário, sob o fundamento da nulidade das provas, haja vista que o intercâmbio de informações financeiras entre o COAF e os órgãos de investigação, sem autorização judicial, viola o sigilo bancário e, por conseguinte, a privacidade dos investigados;

D deferir parcialmente o pedido de quebra de sigilo bancário apenas quanto ao alvo Alfredo e anular as provas quanto ao casal Ferdinando e Imelda e às sociedades empresárias, porque o COAF não pode, espontaneamente, enviar informações financeiras aos órgãos de investigação;

E indeferir o pedido, sob o fundamento da nulidade das provas, porque a ilegalidade da atuação espontânea do COAF em relação aos investigados Ferdinando e Imelda e suas sociedades empresárias contamina os demais elementos de convicção presentes na investigação.

Na prova do MPSC para o cargo de promotor foi cobrada a seguinte questão:

Ano: 2026 Banca: [VUNESP](#) Órgão: [MPE-SC](#) Prova: [VUNESP - 2026 - MPE-SC - Promotor de Justiça Substituto](#)

Adaptada () No julgamento do Tema 990, o STF firmou o entendimento de que é constitucional o compartilhamento de relatórios de inteligência da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e da Receita Federal com os órgãos de persecução penal para fins criminais, independentemente de prévia autorização judicial. Tal intercâmbio dispensa rigores formais, desde que seja preservado o sigilo das informações e assegurado o posterior controle jurisdicional.

O tema foi cobrado nas provas discursivas do MPU/2025 e TJSC/2025 (Sentença).

Posteriormente, por meio de julgado capitaneado pelo Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª Turma, julgado em 15/08/2023, entendeu que a tese firmada no tema 990 não abrangeria os relatórios do COAF, solicitados pelos órgãos de persecução, assim entendeu-se que é ilícito aos órgão persecução penal requisitarem diretamente os RIFs da UIF sem autorização judicial.

PENAL. PROCESSO PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1º, § 2º, I, DA LEI N. 9.613/1998). RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA DO COAF. SITUAÇÃO DIVERSA DA DECIDIDA NO RE N. 1.055.941/SP. RELATÓRIOS SOLICITADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL DIRETAMENTE AO COAF SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.055.941/SP, em âmbito de repercussão geral, fixou as seguintes teses, a saber: "1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional;

2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios."

2. Constatou-se que foi julgado lícito o compartilhamento de provas entre o UIF (antigo **COAF**) e a Receita Federal do Brasil (RFB) com os órgãos de persecução penal, nos casos em que o UIF e a RFB constatarem a ocorrência de ilegalidades e comunicam os fatos aos órgãos de persecução penal.

3. No presente caso, a autoridade policial solicitou diretamente ao **COAF** o envio dos relatórios de inteligência financeira, sem a existência de autorização judicial, situação, portanto, diversa da análise pelo STF.

4. A Terceira Seção desta Corte Superior analisou situação similar, ao julgar o RHC n. 83.233/SP, no qual o Ministério Público requisitou diretamente à Receita Federal do Brasil o envio da declaração de imposto de renda de determinadas pessoas, o que foi considerado ilícito por esta Corte Superior.

5. Dessa forma, o presente recurso em habeas corpus deve ser provido para declarar a ilicitude dos relatórios de inteligência financeira solicitados diretamente pela autoridade policial ao **COAF**.

6. Recurso em habeas corpus provido.

Ocorre que o STF, no âmbito da Rcl 61944 AgR / PA – PARÁ de relatoria do Min. CRISTIANO ZANIN, 1ª Turma, julgamento: 02/04/2024, entendeu que não é legítima a diferenciação operada pelo STJ:

(...)

II – No Tema 990/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o **COAF** e as autoridades de persecução penal sem necessidade de prévia autorização judicial, inclusive com a possibilidade de solicitação do material ao órgão de inteligência financeira. III – No caso em análise não foi demonstrada a existência de abuso por parte das autoridades policiais, do Ministério Público ou a configuração do fishing expedition. IV – Eventual interpretação diversa somente seria possível pelo revolvimento de fatos e provas, o que não é admitido em reclamação. V – Agravo regimental desprovido.

UNIFORMIZAÇÃO DO ENTENDIMENTO NO STJ SOBRE A REQUISIÇÃO DIRETA DE RIFS

Em 28 de maio de 2025, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RHC 196.150/GO, uniformizou a jurisprudência das Turmas criminais da Corte no sentido de que a Polícia e o Ministério Público não podem requisitar diretamente ao COAF Relatórios de Inteligência Financeira – RIFs sem prévia autorização judicial.

Segundo o entendimento prevalecente, a tese fixada pelo STF no Tema 990 da repercussão geral autoriza o compartilhamento, independentemente de ordem judicial, quando a iniciativa parte dos próprios órgãos de inteligência ou fiscalização. Assim, constatada situação

suspeita no exercício de suas atribuições, COAF e Receita Federal podem encaminhar espontaneamente as informações aos órgãos de persecução penal.

A Terceira Seção, contudo, distinguiu essa hipótese daquela em que ocorre o chamado compartilhamento provocado, isto é, quando a Polícia ou o Ministério Público solicita diretamente ao COAF a elaboração ou o fornecimento do RIF. Para o STJ, o Tema 990 não teria autorizado expressamente essa “via inversa”, razão pela qual a obtenção do relatório mediante solicitação direta do órgão de persecução penal depende de prévia autorização judicial.

O entendimento foi fundamentado, entre outros aspectos, na proteção constitucional da privacidade e dos dados pessoais e na interpretação do art. 15 da Lei nº 9.613/1998. Conforme destacou o Min. Messod Azulay Neto, o COAF não possui atribuição para promover quebra de sigilo bancário ou fiscal, mas recebe informações legalmente encaminhadas por entidades obrigadas, processa esses dados e, identificando operações suspeitas, comunica os órgãos competentes.

Desse modo, segundo a orientação uniformizada pelo STJ:

- COAF/RFB → Polícia ou Ministério Público, por iniciativa do órgão de inteligência ou fiscalização: admite-se o compartilhamento sem prévia autorização judicial, nos termos do Tema 990/STF.
- Polícia ou Ministério Público → solicitação direta ao COAF para obtenção de RIF: exige-se, segundo a Terceira Seção do STJ, prévia autorização judicial.

No caso concreto do RHC 196.150/GO, a autoridade policial havia solicitado diretamente ao COAF, sem autorização judicial prévia, relatório financeiro sigiloso que posteriormente subsidiou a investigação e a denúncia. A Terceira Seção reconheceu a ilicitude do RIF e determinou a anulação do relatório e das provas dele derivadas, embora tenha mantido o prosseguimento da ação penal quanto aos elementos probatórios independentes.

Atenção: a própria Terceira Seção registrou que essa orientação prevaleceria no âmbito do STJ até manifestação definitiva do Plenário do STF sobre a extensão do Tema 990, especialmente quanto à possibilidade de requisição direta dos RIFs pelos órgãos de persecução penal. Portanto, trata-se de uniformização interna do STJ, e não de encerramento definitivo da controvérsia no sistema jurisprudencial brasileiro.

SUSPENSÃO NACIONAL E DISCIPLINA PROVISÓRIA DO TEMA 1.404/STF

Após o reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.404, o Min. Alexandre de Moraes, em 20/8/2025, determinou a suspensão nacional dos processos que discutem a validade da obtenção de Relatórios de Inteligência Financeira e de dados fiscais mediante requisição dos órgãos de persecução penal sem autorização judicial e/ou sem prévia instauração de procedimento investigatório formal.

Posteriormente, em 25/8/2025, o relator delimitou o alcance da medida, esclarecendo que a suspensão não impede o prosseguimento das investigações criminais nem alcança decisões que tenham reconhecido a validade das requisições de RIFs. Por outro lado, ficaram suspensos os efeitos de decisões que determinaram a anulação dos relatórios ou dos procedimentos fiscais e o consequente desentranhamento dos elementos investigativos.

Em 27/3/2026, enquanto ainda pendente o julgamento definitivo do Tema 1.404, o relator estabeleceu requisitos provisórios para as novas requisições de RIFs, exigindo:

- investigação formalmente instaurada,
- identificação do investigado e pertinência entre o pedido e o objeto da investigação

- Vedar requisições genéricas e *fishing expedition*.
- O RIF não poderá constituir a primeira ou única medida investigativa.

Em decisão de 21/4/2026, esclareceu-se que esses novos parâmetros possuem eficácia prospectiva (*ex nunc*), não produzindo invalidação automática das requisições anteriormente realizadas, cuja legalidade deverá ser examinada concretamente.

A suspensão nacional permanece vigente enquanto não houver julgamento definitivo do Tema 1.404, conforme consta atualmente no próprio cadastro de repercussão geral do STF.

PROVAS PRODUZIDAS NO ESTRANGEIRO.

Por fim, o STJ reconheceu também a **validade da utilização de provas produzidas no estrangeiro em processos brasileiros**, desde que sejam amplamente cumpridas as disposições da LIND:

Art. 13. A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar, quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça.

Art. 17. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes.

Vejamos o entendimento do referido tribunal:

[...] 2. A provas obtidas por meio de cooperação internacional em matéria penal devem ter como parâmetro de validade a lei do Estado no qual foram produzidas, conforme a previsão do art. 13 da LINDB. 3. A prova produzida no estrangeiro de acordo com a legislação de referido país pode, contudo, não ser admitida no processo em curso no território nacional se o meio de sua obtenção violar a ordem pública, a soberania nacional e os bons costumes brasileiros, em interpretação analógica da previsão do art. 17 da LINDB. [...] 6. Na presente hipótese, as provas encaminhadas ao MP brasileiro são legítimas, segundo o parâmetro de legalidade suíço, e o meio de sua obtenção não ofende a ordem pública, a soberania nacional e os bons costumes brasileiros, até porque decorreu de circunstância autônoma interveniente na cadeia causal, a qual afastaria a mancha da ilegalidade existente no indício primário. Não há, portanto, razões para a declaração de sua inadmissibilidade no presente processo. (APn 856/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/10/2017).

Por fim, um último questionamento:

Qual o valor da prova emprestada no processo em que ingressa?

Inicialmente, considerando o sistema do livre convencimento motivado existente no ordenamento jurídico brasileiro, tratar a respeito do valor de determinada prova não se mostra produtivo, contudo, é tema tratado no âmbito da doutrina, inclusive possibilitando a aplicação analógica do artigo 372, CPC:

Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.

Vejamos os ensinamentos de Renato Brasileiro a respeito:

*Embora seja trazida ao segundo processo pela forma documentada, **a prova emprestada tem o mesmo valor da prova originalmente produzida**. Ou seja, apesar de sempre ter a forma documental, o valor probante da prova emprestada "é o da sua essência, e esta será sempre a originária, consoante foi produzida no processo primitivo". Assim, no exemplo citado acima, conquanto o depoimento de "Mévio" seja trazido ao segundo processo por meio de uma certidão extraída do processo original, seu valor probatório será o de prova testemunhal (Lima, 2018).*

Por fim, um último questionamento. Imagine que o processo em que a prova foi originalmente produzida tenha sido declarado nulo. A prova dele originário poderia ser utilizada em outro processo a título de prova emprestada?

A nulidade do processo originário gera a nulidade de todas as provas nele produzidas?

Utilizando-se as lições do professor Madeira, há duas situações distintas:

- a. Se no processo originário for reconhecida a nulidade ou ilicitude da prova – Nesse caso, não será possível, por questões lógicas, a prova em processo distinto.
- b. Se a nulidade do processo ocorrer por questões não atinentes a prova - Nesse caso, não há óbice para a utilização da prova em processo distinto.

O tema referente às provas emprestadas tem sido frequentemente cobrado em provas, vejamos:

Ano: 2024 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: DPE-AC Prova: CESPE / CEBRASPE - 2024 - DPE-AC - Defensor Público. ²¹

No que se refere à prova emprestada, conforme as normas do direito processual penal brasileiro, julgue os próximos itens.

I É inadmissível a utilização de prova emprestada quando as partes forem diferentes.

II É assegurada a utilização de prova emprestada, desde que seja assegurado às partes o direito de manifestação acerca do teor dos elementos compartilhados.

III Não pode ser admitida prova emprestada se produzida em inquérito distinto daquele no qual se pretende utilizá-la.

Assinale a opção correta.

- a. Apenas o item II está certo.
- b. Apenas o item III está certo.
- c. Apenas os itens I e II estão certos.
- d. Apenas os itens I e III estão certos.
- e. Todos os itens estão certos.

²¹ Gabarito: A.

O tema foi novamente enfrentado na prova do Ministério Público do Estado da Bahia no ano de 2023, vejamos:

Adaptada () Segundo a jurisprudência do STJ, a absoluta identidade de partes entre o processo de que se empresta a prova e o processo para o qual esta é emprestada é necessária para a observância do devido processo legal e do contraditório.²²

O tema também já foi objeto de cobrança na prova discursiva do Ministério Público Federal, vejamos:

(MPF) - Procurador da República/2013. Discorra sobre prova emprestada no processo penal: conceito, limitações e jurisprudência.

PROVAS CAUTELARES, NÃO REPETÍVEIS E ANTECIPADAS E ANÁLISE DO ART. 155, CPP.

Dentro do estudo da teoria geral das provas, é necessário o estudo do artigo 155, CPP, o qual possui a seguinte redação.

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.

Para que possamos analisar esse dispositivo, inicialmente, deve-se conceituar com clareza o sentido das provas Cautelares, Irrepetíveis e Antecipadas.

As **Provas Cautelares** são aquelas que seguem o modelo das demais medidas cautelares previstas no ordenamento jurídico processual, as quais se concretizam pelo “*fumus commissi delicti e periculum in mora*”. O risco da demora ou desaparecimento é a característica mais marcante das provas cautelares, as quais, ordinariamente, submetem-se à cláusula de reserva jurisdicional. Podem ser produzidas tanto na fase inquisitória, o que é mais comum, ou na fase processual, em ambas as situações o contraditório é exercido de forma diferida ou postergada.

As **Provas Não Repetíveis** (irrepetíveis) são aquelas que, uma vez produzidas, não são passíveis de renovação, motivo pelo qual também possuem o elemento urgência como fenômeno diretamente correlacionado. Estar-se-á a falar, normalmente, dos exames periciais. Não se sujeitam à cláusula de reserva jurisdicional e também contam com contraditório diferido ou postergado.

O tema foi cobrado na prova do MPDFT, vejamos a questão adaptada:

²² Gabarito: Errado.

() As perícias produzidas no inquérito precisam ser repetidas no curso da ação penal para que possam serem utilizadas como base de condenação, nos moldes do artigo 155 do CPP.²³

O STJ tem sucessivamente manifestado-se a respeito das provas irrepitíveis, vejamos alguns julgados recentes:

Reconhecimento de Pessoas - Prova Irrepetível.

ATENÇÃO: a irrepitibilidade não decorre necessariamente do desaparecimento físico do objeto da prova. No Tema 1.258, o STJ reconheceu que o reconhecimento de pessoas possui natureza irrepitível em razão do risco de contaminação da memória do reconhecedor. Um reconhecimento inicial viciado pode comprometer o procedimento posterior, ainda que este venha a observar formalmente o art. 226 do CPP.

1) As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2) Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3) O reconhecimento de pessoas é prova irrepitível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda aos ditames do art. 226 do CPP.

4) Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5) Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6) Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas

²³ Gabarito: Errado.

percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

[REsp 1.953.602-SP](#), Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 11/6/2025, DJEN 30/6/2025. ([Tema 1258](#)). [REsp 1.987.628-SP](#), Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 11/6/2025, DJEN 30/6/2025 ([Tema 1258](#)). [REsp 1.986.619-SP](#), Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 11/6/2025, DJEN 30/6/2025 ([Tema 1258](#)). [REsp 1.987.651-RS](#), Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 11/6/2025, DJEN 30/6/2025 ([Tema 1258](#)).

Em outra oportunidade, irrepetibilidade da testemunha que faleceu antes da instrução processual.

No AgRg no RHC 227.441, publicado em 30/3/2026, o STJ enfrentou um homicídio em que uma testemunha havia prestado depoimento durante o inquérito e faleceu antes da instrução judicial.

A Corte decidiu:

O depoimento prestado na fase policial por testemunha que venha a falecer antes da instrução constitui prova irrepetível. Brasília, 25 de março de 2026 . JOEL ILAN PACIORNIK.

Teste de etilômetro.

No AgRg no AREsp 3.128.529/AP, Quinta Turma, julgado em maio de 2026, discutia-se o crime de embriaguez ao volante. Havia teste de etilômetro, considerado prova irrepetível, mas os policiais ouvidos em juízo já não se recordavam de quem dirigia o veículo. O STJ afirmou:

A prova irrepetível pode ser valorada, mas não supre a ausência de prova judicial da autoria.

O etilômetro demonstrava a alcoolemia da pessoa submetida ao exame, mas isso não solucionava, por si só, a questão de saber se era efetivamente ela quem conduzia o automóvel.

O resultado foi a manutenção da absolvição.

Brasília, 12 de maio de 2026 . Ministro Ribeiro Dantas.

Exame Clínico como Prova Irrepetível.

O AgRg no AREsp 3.122.302, publicado em 12/5/2026, o STJ reconheceu que exame clínico médico realizado logo após o fato possui natureza de prova irrepetível e pode ser valorado para fins de pronúncia, em conjunto com outros elementos produzidos sob contraditório.

Por fim, as **Provas Antecipadas** são aquelas que devem ser produzidas antes do momento devido para a produção probatório em incidente próprio e com contraditório contemporâneo. Vejamos os dispositivos que fazem referência a esse tipo de prova:

Art. 225. Se qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento.

Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no [art. 312](#). [\(Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996\)](#)

O disposto no artigo 366 também é frequente em provas, o assunto é rotineiramente cobrado em certames públicos, inclusive é alvo de análise por parte do STJ, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSO PENAL.
ESTELIONATO. **PROVAS ANTECIPADAS**. LEGALIDADE. SÚMULA N. 455/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo" (Súmula n. 455/STJ, Terceira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 8/9/2010.) 2. No caso, a decisão que determinou a produção antecipada da prova encontra-se concretamente fundamentada, tendo sido apontado, além do decurso de tempo, a falibilidade da memória dos depoentes e a possibilidade de que elementos relevantes sobre o fato narrado na denúncia, ocorrido em 2018, não fossem trazidos à lume pelas testemunhas. Ademais, não houve demonstração objetiva de prejuízo à defesa decorrente da realização da diligência em apreço, nos termos do art. 563 do CPP.
2. (...)
3. AgRg no RHC 120631 / BA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2019/0344763-7, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 09/08/2022.

O Tema foi cobrado na prova do Ministério Público do Estado de Goiás no ano de 2026, vejamos:

Ano: 2026 **Banca:** [FGV](#) **Órgão:** [MPE-GO](#) **Prova:** [FGV - 2026 - MPE-GO - Promotora e Promotor de Justiça Substituto](#) ²⁴

O Ministério Público do Estado de Goiás ofereceu denúncia em face de Caio pela suposta prática do crime de extorsão mediante sequestro. Após a observância de todas as formalidades legais, designou-se data para a realização da instrução processual. No dia da audiência, o acusado não compareceu, embora sua defesa constituída estivesse presente. Ao analisar os autos, as partes da relação processual constataram que Caio mudou de residência, não tendo comunicado o novo endereço ao juízo.

²⁴ Gabarito: E.

Nessa conjuntura, considerando as disposições do Código de Processo Penal, é correto afirmar que a audiência de instrução será

A suspensa, devendo Caio ser intimado da data da próxima audiência por meio da defesa constituída.

B suspensa, devendo Caio ser intimado da data da próxima audiência por carta precatória.

C realizada sem a presença do acusado, desde que haja concordância da defesa constituída.

D suspensa, devendo Caio ser intimado da data da próxima audiência por edital.

E realizada sem a presença do acusado, com a decretação de sua revelia.

Ano: 2026 **Banca:** [FGV](#) **Órgão:** [TJ-SC](#) **Prova:** [FGV - 2026 - TJ-SC - Oficial de Justiça e Avaliador](#)

Em um processo que apura a prática de crime de estelionato, o oficial de justiça tentou localizar o réu nos endereços constantes nos autos, sem sucesso. Após certificar que o réu se encontra em local incerto e não sabido, o magistrado determinou a citação por edital. O edital foi publicado com prazo de 15 dias, mas, decorrido o prazo, o réu não compareceu e não constituiu advogado para representá-lo.

Diante de tal situação hipotética, assinale a afirmativa correta.

A O juiz deverá nomear defensor dativo e dar prosseguimento ao processo até a sentença, uma vez que a citação por edital é válida para fins de prosseguimento da ação.

B O processo deverá ser suspenso, assim como o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva.

C A citação por edital é considerada nula se não for precedida de citação por hora certa, devendo o juiz determinar nova diligência antes de qualquer decisão sobre a suspensão do feito.

D O juiz deve declarar a revelia do réu e encaminhar os autos ao Ministério Público para que o órgão realize a busca do endereço atualizado, mantendo-se o curso da prescrição.

E Por se tratar de crime de estelionato, a suspensão do processo depende de prévia concordância da vítima, que deverá ser intimada para manifestar interesse no prosseguimento da lide.

Vejamos dispositivo do CPC que trata especificamente a respeito da produção antecipada de provas:

Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

O tema é frequente em provas:

MPPR/2025.²⁵

²⁵ Gabarito: E

() A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do Código de Processo Penal pode ser fundamentada unicamente no decurso do tempo para se ter como urgente a antecipação probatória.

Foi cobrado na prova objetiva do Ministério Público do Estado do Paraná, vejamos:

Ano: 2021 Banca: MPE-PR Órgão: MPE-PR Prova: MPE-PR - 2021 - MPE-PR - Promotor de Justiça Substituto:

Quanto ao tema das provas, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa:

I - Provas cautelares são aquelas produzidas com a observância do contraditório real, perante a autoridade judicial, em momento processual diverso daquele legalmente previsto, ou até mesmo antes do início do processo.

II - Provas antecipadas são aquelas produzidas quando há risco do desaparecimento do objeto da prova em razão do decurso do tempo, em relação às quais o contraditório será diferido.

III - A interceptação telefônica é exemplo de prova cautelar.

IV – Fonte de prova é uma expressão utilizada para se referir às pessoas ou coisas pelo meio das quais se obtém a prova, ou seja, cometido o fato delituoso, tudo o que possa servir para elucidar a existência desse fato pode ser conceituado como fonte de prova.

V - A prova colhida em razão da suspensão do processo e do curso da prescrição em relação ao acusado citado por edital, que não tenha comparecido nem constituído defensor é um exemplo de prova antecipada.

Alternativas

- A. Todas as assertivas estão corretas.
- B. Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
- C. Apenas as assertivas III, IV e V estão corretas.
- D. Apenas as assertivas II, III e V estão corretas.
- E. Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.

(MPDFT) - Promotor de Justiça (MPDFT)/2013/30º. Interprete o seguinte dispositivo legal, extraíndo-lhe todos os significados possíveis, particularmente em relação aos termos destacados abaixo. Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

(MPE PR) - Promotor de Justiça/2017. Acerca da prova no processo penal: A) Defina o que são provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, esclarecendo se a legislação processual penal permite que sejam utilizadas na formação da convicção

do julgador (valoração como material probante) quando produzidas na fase de investigação. B) Leia a hipótese do Enunciado a seguir e responda, fundamentadamente, se está correta a pretendida solução absolutória requerida por ausência de prova da materialidade. ADELICIO LIMA SILVA foi denunciado e processado por estupro de vulnerável (art. 217- A, do Código Penal), sob a acusação de ter praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a criança A.F.R., de 10 (dez) anos de idade, consistente em acariciar e beijar a vagina da infante. No transcorrer da instrução, sobreveio aos autos o laudo de exame pericial a que foi submetida à vítima, com "resposta prejudicada" para os questionamentos realizados quanto à ocorrência de atos libidinosos, embora a prova testemunhal fosse harmoniosa e robusta no sentido da sua prática. Ao apresentar alegações finais do acusado ADELICIO LIMA SILVA, a Defesa pleiteia a sua absolvição, invocando, como fundamento, a ausência de comprovação da materialidade delitiva diante da inexistência de laudo de exame pericial positivo.

Ainda a respeito da prova antecipada, o STJ entendeu que é justificável, em caso de depoimento especial de criança ou adolescente, a produção de prova antecipada²⁶:

É justificável a antecipação de prova no caso de depoimento especial de adolescente vítima de possível crime sexual - na forma da Lei nº 13.431/2017 - pela relevância da palavra da vítima em crimes dessa natureza e na sua urgência pela falibilidade da memória de crianças e adolescentes.

STJ. 5ª Turma. AgRg no RHC 160012/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, julgado em 6/3/2023 (Info 767).

Em outro julgado bastante relevante, o STJ admitiu a produção antecipada de provas para oitiva de policiais²⁷:

É possível a antecipação de provas para a oitiva de testemunhas policiais, dado que, pela natureza dessa atividade profissional, diariamente em contato com fatos delituosos semelhantes, o decurso do tempo traz efetivo risco de perecimento da prova testemunhal por esquecimento.

STJ. 6ª Turma. AgRg no AREsp 1995527-SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 19/12/2022 (Info 764).

Esse tema foi cobrado na prova do Ministério Público do Distrito Federal no ano de 2025, vejamos:

²⁶ CAVALCANTE, Márcio André Lopes. **É justificável a antecipação de prova no caso de depoimento especial de adolescente vítima de crime sexual, pela relevância da palavra da vítima em crimes dessa natureza e na sua urgência pela falibilidade da memória de crianças e adolescentes.** Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/88ceeb0496aa9e60b4b6b6a5d4fe3648>>. Acesso em: 22/05/2023

²⁷ CAVALCANTE, Márcio André Lopes. **É possível a antecipação de provas para a oitiva de testemunhas policiais.** Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: <<https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/acf8b366843afe53ac7efe9af8c1b90b>>. Acesso em: 22/05/2023

() Em razão de possível esquecimento, é válida a produção antecipada de provas de agentes policiais, fundamentada unicamente no transcurso do tempo e da quantidade de ocorrências similares atendidas cotidianamente.²⁸

É importante ainda observarmos que o STJ tem entendido que a produção antecipada de provas não apresenta prejuízo à defesa, vejamos:

A realização antecipada de provas não traz prejuízo ínsito à defesa, visto que, a par de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, nada impede que, retomado eventualmente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas provas que se julgarem úteis à defesa, não sendo vedada a repetição, se indispensável, da prova produzida antecipadamente.
STJ. 3ª Seção. RHC 64086-DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Rel. para acórdão Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 23/11/2016 (Info 595).

Esse tema tem sido frequente em provas:

(Cespe/DPE/PE/Defensor/2018) No caso de citação por edital, se o acusado não comparecer e não constituir advogado, o processo poderá prosseguir seu curso normal, desde que para ele seja nomeado defensor público. (errado)

(Cespe/TI/PA/Analista/2020) Se um acusado, citado por edital, não comparecer para defender-se em ação penal pelo crime de falsidade ideológica, nem constituir advogado, o juiz poderá determinar a produção de provas consideradas urgentes. (certo)

(MPE/PR/Promotor/2019) Se o acusado, citado por edital ou por hora certa, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. (errado)

(FCC/DPE/AM/Defensor/2018) A gravidade do delito e o decurso de tempo justificam a antecipação da prova oral, porquanto a sua urgência decorre da natureza da prova testemunhal, existindo direito público subjetivo da acusação à sua produção antecipada. (errado)

É interessante observar que doutrina e jurisprudência aceitam a possibilidade de que os elementos informativos sejam utilizados na atividade decisória do magistrado, desde que o façam de modo subsidiário.

Os elementos informativos podem contribuir na atividade decisória, contudo não podem ser utilizados como elemento principal ou único da atividade cognitiva.

Vejamos alguns precedentes nesse sentido:

INQUÉRITO - ELEMENTOS - CONDENAÇÃO. Surge insubsistente pronunciamento condenatório baseado, unicamente, em elementos coligidos na fase de inquérito. (HC 96356, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2010). [...]
INQUÉRITO.

²⁸ Questão – Correta.

CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO DOS TESTEMUNHOS PRESTADOS NA FASE INQUISITORIAL. [...] Ao contrário do que alegado pelos ora agravantes, o conjunto probatório que ensejou a condenação dos recorrentes não vem embasado apenas nas declarações prestadas em sede policial, tendo suporte, também, em outras provas colhidas na fase judicial. Confirmação em juízo dos testemunhos prestados na fase inquisitorial. 4. Os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo. 5. Agravo regimental improvido. (RE 425734 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 04/10/2005).

Somente a título de aprofundamento, Paulo Rangel²⁹ possui posicionamento em sentido contrário, vejamos:

“O art. 155 ressalta que o juiz não poderá fundamentar sua decisão, exclusivamente, nos elementos informativos colhidos na investigação. Pode acontecer de o intérprete açodado entender que a palavra exclusivamente significa dizer que o juiz pode sopesar as provas do inquérito desde que em cotejo com as demais provas do processo. Nada mais equivocado. A palavra exclusivamente significa dizer que o juiz não deve levar em consideração, em sua sentença, as informações contidas no inquérito policial, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Não servem nem para cotejá-las com as do processo. Prova de inquérito é para que o MP possa dar o pontapé inicial, oferecendo denúncia.

ÔNUS DA PROVA.

CONCEITO.

Antes de efetivamente ingressarmos no conceito de ônus processual, é interessante diferenciarmos conceitos correlatos: faculdade processual, direito subjetivo, dever jurídico / obrigação e direito postestativo / poder jurídico, para esse desiderato nos valeremos das lições apresentadas pelo professor Afrânio Jardim:

*Entende-se como **faculdade jurídica** a possibilidade de fazer tudo quanto a lei não proíba e de omitir tudo quanto ela não imponha. É um campo de liberdade jurídica, decorrente da irrelevância para o direito ou da inexistência de ilicitude. Já o chamado **direito subjetivo**, numa apreciação superficial, é mais do que uma mera faculdade de fazer ou não fazer. **É faculdade de exigir de outrem uma prestação.** Assim, em sendo bilateral, ao direito subjetivo corresponde o dever jurídico ou obrigação. Chama-se **direito potestativo ou poder jurídico** a faculdade, assegurada pela norma jurídica, de o seu titular submeter terceiro à sua vontade. Vale dizer, unilateralmente atinge-se a esfera jurídica do sujeito passivo, que a tudo fica submetido. Aqui, ao invés de dever ou obrigação, temos uma posição de **mera sujeição à vontade de outrem**. Finalmente, chegamos ao ônus processual. Não é ele bilateral, o que torna fácil distingui-lo do direito subjetivo e poder jurídico.*

²⁹ Direito processual penal, 26ª ed., São Paulo: Atlas, 2018.

O ônus não é algo impositivo, imperativo. Muito pelo contrário, é uma espécie de faculdade. É um campo de liberdade que tem um determinado sujeito de direito para atuar positivamente, a fim de que venha a alcançar algum benefício em seu favor. Assim, pode-se dizer que ônus processual é uma faculdade outorgada pela norma para que um sujeito de direito possa agir no sentido de alcançar uma situação favorável no processo. Se juridicamente fosse possível, poderíamos dizer que ônus “é o dever para consigo mesmo” (Jardim, 2003).

Ainda a respeito da conceituação de ônus processual, as lições do professor Hélio Tornaghi são elucidativas, vejamos:

“não se trata de um dever, mas de um ônus, um encargo. O dever existe para com outrem. Quem o tem e não o cumpre sofre pena. O encargo é uma sorte de obrigação para consigo mesmo. Se a lei encarrega alguém de praticar um ato, em seu próprio favor, e o encarregado não o realiza, a ninguém prejudica senão a si mesmo. Por isso não sofre pena; deixa de lucrar o que ganharia se o praticasse”.

NORBERTO AVENA arremata o tema, ocasião em que relata que “por ônus entende-se o encargo atribuído às partes de provar, por meio de meios lícitos e legítimos, a verdade das suas alegações, visando, assim, a fornecer ao juiz os elementos necessários à formação de sua convicção”.

ÔNUS DA PROVA OBJETIVO E SUBJETIVO.

O **ônus da prova subjetivo** é encargo atribuído às partes e refletem **regras de conduta e comportamento** quando ao **ônus de prova suas alegações**. Já o **ônus objetivo** é inerente ao juiz e reflete-se em **regras de julgamento**, as quais devem ser aplicadas pelo juiz quando as partes não conseguem com clareza formar a necessária cognição do juiz para um decreto decisório.

Afrânio Jardim fala a esse respeito:

“a utilidade prática das regras sobre o ônus da prova está em fornecer ao Juiz critérios legais para que possa decidir mesmo diante de fatos incertos. Malgrado todo o empenho das partes e do Juiz em buscar determinada prova, constantemente ocorre que persiste dúvida sobre ponto relevante para o julgamento da pretensão punitiva. Aqui é que está o cerne da questão, pois o magistrado não pode escusar-se de julgar e, em nosso direito, não existe o instituto da suspensão do processo penal por insuficiência de provas”.

O mesmo autor destaca que “quanto mais subsídios de provas existirem, quanto maior a probabilidade de um esclarecimento cabal dos fatos relevantes, na mesma proporção diminuirá a necessidade de recorrer às normas de distribuição do onus probandi. As regras do ônus da prova, consideradas como regras de julgamento, implicam na repartição do risco da prova, que é a solução necessária para os casos de impossibilidade de esclarecimento, apesar de todos os esforços (Jardim, 2003).

Com menor incidência na doutrina, Renato Brasileiro ainda fala em ônus perfeito e ônus menos perfeito, vejamos as lições:

Ônus da prova perfeito e menos perfeito. Tendo como critério a consequência que decorre do não cumprimento do ônus, a doutrina o subdivide em ônus perfeito e menos perfeito. O ônus é perfeito quando o prejuízo, que é o resultado de seu descumprimento, ocorre necessária e inevitavelmente. Um ônus é tido como menos perfeito quando os prejuízos que derivam de seu descumprimento se produzem de acordo com a avaliação judicial. Com base nessa classificação, não se pode falar em ônus completamente imperfeito, na medida em que, quando não resultar qualquer prejuízo da inação para o omitente, não haverá ônus algum.

DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.

O tema é controverso na doutrina, motivo pelo qual faremos detalhada análise a respeito do tema.

Inicialmente, devemos observar a literalidade do artigo 156, CPP, vejamos a redação do dispositivo legal:

*Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:
(...)*

É relevante ressaltar que o referido dispositivo faz referência à fase judicial, pois, na fase investigativa, a participação do investigado ou vítima não é tão incisiva, nos termos do artigo 14, CPP:

Art. 14. O ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será realizada, ou não, a juízo da autoridade.

O art. 156 deve ser lido em consonância com o disposto no artigo 386, CPP, vejamos:

*Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
II - não haver prova da existência do fato; [...]
V - não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;
[...]*

A partir da leitura dos referidos dispositivos legais, duas correntes se formaram a respeito da distribuição do ônus da prova:

Ônus da prova distribuído entre acusação e defesa.

Ônus da prova estático, incumbindo somente à acusação o ônus probatório.

ÔNUS DA PROVA DISTRIBUÍDO.

A doutrina majoritária entende que o ônus da prova, conjugando a leitura do artigo 156 e 386, deve ser distribuído entre as partes. O CPC possui dispositivo bastante elucidativo a respeito do tema, vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

-
- I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;*
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, prevalece que à acusação se incumbe o ônus de provar a materialidade e a autoria, “cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela acusação” (Dezem, 2018).

Vejamos algumas passagens das obras de autores que se posicionam nesse sentido:

Hélio Tornaghi:

O art. 156 do Código de Processo Penal é claro, porém menos preciso do que parece à primeira vista. Se o acusador afirma que o acusado matou e este assevera que não o fez, a quem compete a prova? Se o autor assegura que o acusado agiu ilicitamente e o réu sustenta que agiu lícitamente, qual dos dois deve provar? Seria errado supor que o acusador tem de provar tudo quanto alega contra o réu. Assim, por exemplo, não lhe é necessário provar a ilicitude do fato, desde que ele seja típico, isto é, adequado à descrição legal. O promotor denuncia Tício por haver morto Caio, não precisa provar que ele o fez antijuridicamente. Ao contrário: Tício, o denunciado, é que terá de provar que o fato por ele praticado, apesar de típico, foi lícito (por exemplo, por ter agido em legítima defesa).

Frederico Marques:

(...) Deduz-se de ambos os preceitos que à parte acusadora incumbe fornecer os necessários meios de prova para a demonstração da existência do corpus delicti e da autoria. Daí se segue que todos os elementos constitutivos devem ter sua existência provada, ficando o onus probandi, no caso, para a acusação. Cabe a esta demonstrar não só a chamada materialidade do crime (o que é a função do auto de corpo de delito), como ainda os elementos subjetivos e normativos do tipo (...)

[...] O Ministério Público deve provar a prática do fato típico. Feita essa demonstração fundamental, segue-se o juízo de valor sobre a licitude da conduta tipificada. Existindo uma causa excludente da antijuridicidade, o fato típico não será ilícito. Ao réu, porém, incumbe provar a existência dessa causa excludente de ilicitude, para que demonstre ter agido secundum jus. [...] Idêntico fenômeno ocorre com o ônus da prova no tocante às causas de exclusão da culpabilidade mencionadas no art. 386 [...]. Quando se trata de culpa, a sua inserção no tipo [...] faz com que o onus probandi seja do Ministério Público, quer se trate de imperícia, de imprudência ou de negligência. A prova do dolo incumbe também à acusação.

Em sentido bastante semelhante se posicionam Mirabete, Nucci, Pacelli, Norberto Avena e Vicente Greco Filho.

ÔNUS DA PROVA EXCLUSIVO DA ACUSAÇÃO.

Para essa corrente não haveria distribuição no ônus probatório, ao contrário, toda o ônus pesaria sobre a acusação. Nesse sentido, vejamos as lições apresentadas por Gustavo Badaró:

No processo penal, diante da garantia constitucional da presunção de inocência, não há distribuição do ônus da prova, que pesa todo sobre a acusação. Trata-se de um ônus da prova unidirecional, não

havendo, pois, distribuição do ônus da prova, como ocorre no processo civil. Além disso, em decorrência da garantia constitucional da presunção de inocência, também não são admitidas no processo penal presunções legais ou judiciais contra o acusado. A doutrina é uniforme no sentido de que a dúvida sobre a conduta típica, incluindo em tal conceito a ação ou a omissão, bem como o nexo causal com o resultado naturalístico, quando estes forem exigíveis, levará a um julgamento absolutório. O ônus da prova da autoria delitiva, bem como da participação no concurso de agentes, pesa sobre a acusação. Curiosamente, contudo, tem prevalecido na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que, se o acusado alega um alibi, pesaria sobre ele o ônus da prova de demonstrar que estava em outro lugar, no momento da prática delitiva.

Em sentido contrário, Paulo Rangel, Aury Lopes e Renato Brasileiro.

Desse modo, ao menos de acordo com a doutrina majoritária, poderíamos consolidar o entendimento da seguinte maneira:

Ônus da Acusação:

- Existência do fato relevante penal.
- Autoria.
- Relação de causalidade e materialidade (***nos crimes materiais***).
- Culpa *strictu sensu* e presunção de Dolo.

Ônus da Defesa:

- Fatos impeditivos: exclusão de culpa / ausência de dolo.
- Fatos modificativos: excludentes de ilicitude.
- Fatos extintivos: prescrição.

O professor, WOLFREDO CUNHA CAMPOS, com maestria consolida o entendimento preponderante na doutrina:

[...] o art. 156, caput, do CPP, com meridiana clareza, estatui que a prova da alegação incumbe a quem a fizer; ora, tal dispositivo legal é aplicável tanto à acusação quanto à defesa; nada mais justo que quem alegue comprove o que alegou. Seria supinamente injusto, uma parte processual alegar, gratuita e até levianamente, um fato que a beneficie, sem nada demonstrar a respeito de sua existência, divertindo-se com o ingente esforço do seu adversário processual em comprovar que aquele fato inexistiu! A defesa impõe-se o ônus de demonstrar a ocorrência das causas excludentes de ilicitude, de culpabilidade, do alibi, de extinção da punibilidade, ou de causas de redução de pena; não há que se falar em qualquer violação ao princípio da presunção de inocência na imposição desse ônus a defesa, pois se trata de mera repartição, equânime e justa, do ônus probatório, entre as partes, numa relação jurídica processual, como corolário, no campo do direito processual, do princípio reitor constitucional da igualdade. E tanto inexistiu prejuízo à presunção de inocência que, caso a defesa não se desincumbia com sucesso em comprovar o fato que a beneficie, mesmo assim, surgida dúvida razoável a respeito de sua ocorrência, a alegação será tida como demonstrada; por isso, denomina-se o ônus da defesa, no processo

penal, como ônus imperfeito que tem o significado de ônus cujo não atendimento não acarreta, necessariamente, prejuízo ou perda de vantagem à parte a quem aproveitaria. (...)

NÍVEL PROBATÓRIO EXIGIDO PELA DEFESA.

Considerando as observações que fizemos anteriormente, surge o seguinte questionamento:

A defesa teria então o ônus processual de demonstrar todos os elementos que comprovem que agiu em legítima defesa? Ou de comprovar por A + B que não tinha elemento subjetivo em sua conduta?

Ao analisar esse questionamento, percebe-se que esse seria um ônus desproporcional à defesa. Dessa maneira, considerando o *in dubio pro reo*, a exigência feita à defesa é que gere uma dúvida razoável no magistrado a respeito da ocorrência de causa excludente de ilicitude ou circunstância que afaste o elemento subjetivo da conduta.

Nesse sentido, vejamos as lições apresentadas por Aury Lopes Júnior:

Princípio importantíssimo no Estado Democrático de Direito, a lógica do in dubio pro reo é que se o magistrado, ao analisar o conjunto probatório, permanecer em dúvida sobre a condenação ou absolvição do réu, deve optar pela absolvição, até porque entre duas hipóteses não ideais é menos traumático para o direito absolver um réu culpado do que admitir a condenação de um inocente. Evidentemente, o famoso princípio do in dubio pro reo deve ter sua aplicação limitada no processo penal, uma vez que funciona como regra de julgamento a fim de evitar o non liquet do julgador, sendo certo que o ideal é sempre o juiz julgar com a certeza, seja para condenar ou para absolver.

Nesse sentido, são as disposições do artigo 386, CPP, vejamos:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)

VI – existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1º do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência;

Observa-se que há um pesado ônus para a acusação, o que não pode ocorrer é atribuir a denominada prova diabólica à acusação: *aquela impossível de ser produzida ou que atribuiu um ônus irrazoável a qualquer das partes.*

A esse respeito o professor Flávio Rolim, no âmbito da obra Processo Penal decifrado, esclarece que: *“a doutrina costuma chamar de prova diabólica aquela que, segundo as regras do ônus da prova, se mostra impossível, ou extremamente difícil, a sua realização pela parte a quem incumbe a sua produção. Ocorre diante da necessidade de se prova um fato negativo indeterminado.*

Tem-se chamado prova duplamente diabólica aquela que envolveria situações em que a impossibilidade ou dificuldade para sua colheita abrangeria ambas as partes. São situações de inesclarecibilidade, a serem resolvidas pelo princípio do in dubio pro reo”

O tema já foi cobrado na prova de Juiz Federal da 5ª região no ano de 2017, vejamos:

CESPE - Juiz Federal (TRF 5ª Região)/2017/XIV. Em que consiste a prova diabólica? Quando houver prova bilateralmente diabólica, como deve o juiz proceder? A quem cabe o ônus da prova? Justifique.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

A pergunta a ser respondida nesse tópico é a seguinte:

Seria possível a inversão do ônus da prova no âmbito do processo penal?

Inicialmente, é importante observarmos que, no CPC, há dispositivo expresso a esse respeito, vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando: (...)

Mesmo diante da existência desse dispositivo legal, a resposta à referida pergunta é NÃO.

No âmbito do processo penal, não seria possível a inversão do ônus da prova, a ponto de atribuir à defesa o ônus processual de provar a sua inocência, presumindo-se a sua responsabilidade, sob pena de lhe atribuir a denominada prova diabólica.

Contudo, em determinadas hipóteses, essencialmente nas **cautelares patrimoniais**, atribui-se à defesa um maior ônus no sentido de comprovar a licitude dos bens, alegadamente, proveniente direta ou indiretamente de infração penal.

Nesse sentido, vejamos elucidativo dispositivo contida na Lei de Lavagem de Capitais (Art. 4º, §2º, Lei 9.613/1998):

Art. 4º O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes. [...]

§ 2º O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores quando comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal.

Vejamos, mais uma vez, as esclarecedoras lições apresentadas pelo professor Renato Brasileiro, o qual cita as lições apresentadas por Ada Pellegrini:

Para ADA PELLEGRINI GRINOVER, essa inversão do ônus da prova "seria representada, portanto, por uma carga mais leve para a acusação do que para a defesa, no sentido de que, para o sequestro, bastarão indícios veementes, enquanto para a liberação será necessária a comprovação da licitude, entendida como exigência de prova plena". O preceito em questão merece interpretação conforme, sob pena de evidente violação ao princípio da presunção de inocência, por estabelecer indevida inversão do ônus da prova.

Assim, deve ser entendido como relacionado ao pedido de restituição durante o curso do processo. Se esse pedido de liberação for formulado antes da decisão, recai sobre o réu, corréu, partícipe ou terceiro de boa-fé o ônus de comprovar a licitude da origem dos bens, mediante a oposição dos embargos previstos no art. 130, I e II, do CPP. Já no momento da prolação da sentença condenatória, o ônus quanto à demonstração da ilicitude da origem dos bens volta a recair sobre o Ministério Público, que deverá comprovar a existência de prova de que os bens, direitos ou valores são objeto do delito de lavagem de capitais (Lima, 2018).

Américo Bedê Júnior não concorda com tal posicionamento, ocasião em que relata que a questão não se trata de inversão do ônus em matéria penal, **já que a questão se refere à matéria cível.**

"Mesmo no caso da exigência da comprovação da licitude da origem dos bens, não cabe cogitar de inversão do ônus da prova a cargo do 'acusado', visto não se tratar de prova sobre a existência do crime e sua autoria, mas sim sobre a origem dos bens apreendidos ou sequestrados. (...) A questão versada no processo sumário de restituição de coisas ou de embargos traz o conhecimento sobre matéria distinta daquela que é objeto da ação penal, visto que aborda a legitimidade da posse ou propriedade dos bens, constituindo uma questão diversa daquela que trata da existência do crime e sua autoria, muito embora haja a prejudicialidade desta em relação àquela, porquanto o trânsito em julgado da ação penal deve ser obtido, para se decidir sobre o destino dos bens (art. 122 e art. 130, parágrafo único do CPP).

O PAPEL DO JUIZ NA GESTÃO DA PROVA.

O papel do juiz na gestão da prova encontra-se substanciado no âmbito do artigo 156, CPP, vejamos o texto legal:

Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:

I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida;

II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.

Desse modo, observa-se atividade subsidiária do juiz no que concerne à produção probatória. Nesse sentido, com maestria, se posiciona CAPEZ:

*Note-se, contudo, que, em razão de nosso Código de Processo Penal adotar o sistema acusatório, e não inquisitivo, **tal faculdade de produção de provas pelo magistrado é supletiva**, devendo, pois, ser comedida, nesse sentido, sua atuação. Somente em casos excepcionais, quando a dúvida persistir no espírito do magistrado, é que este poderá dirimi-la, determinando as diligências nesse sentido. Essa pesquisa probatória a ser efetivada pelo juiz deve restringir-se a uma área de atuação por ele delimitada, com o fito de evitar a quebra da imparcialidade (Capez, 2018).*

Da leitura do dispositivo, observa-se a atividade probatória do juiz em dois momentos distintos: fase investigativa e fase processual, analisaremos separadamente cada uma dessas hipóteses.

INICIATIVA DO JUIZ NA FASE INVESTIGATÓRIA.

Vejamos o dispositivo legal:

Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:

I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida;

A leitura que se faz a respeito desse dispositivo é que o juiz poderia, desde que provocado, ordenar a produção de provas consideradas urgentes e relevantes.

A doutrina majoritária sempre foi enfática em criticar a possibilidade de o juiz, de ofício, na fase investigativa, determinar a produção probatória na fase investigativa, sob pena de contaminar-se com elementos que possam influir na sua livre atividade decisória.

Essencialmente, após alterações efetivadas pelo pacote anticrime³⁰:

Art. 3º A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação.

Apesar das severas críticas, a jurisprudência, a título excepcional, admitiu a possibilidade de o juiz atuar de ofício na fase investigativa:

“3. Diante do disposto no art. 156 do CPP, não se reveste de ilegalidade a atuação de ofício do Magistrado que, em pesquisa a banco de dados virtuais, verifica a presença de registros criminais em face do paciente” (STF, HC 126501/MT, rel. Min. Marco Aurélio, j. 14.06.2016).

No mesmo sentido, vejamos outro julgado:

“1. A instância ordinária, à luz das peculiaridades do caso (= estupro de vulnerável cometido contra crianças de 10 e 8 anos de idade), apresentou fundamentação jurídica idônea para justificar a produção antecipada de provas, destacando a urgência, a relevância e a proporcionalidade da medida, nos termos do art. 156, I, do CPP. Não há, portanto, vício de fundamentação.” (STF, RHC 121.494/RS, j. 04.11.2014, rel. Min. Teori Zavascki) (Dezem, 2018).

O professor Rogério Sanches arremata com suas lições:

Observe-se, contudo, que no sistema acusatório, mesmo o juiz das garantias não deve imiscuir-se na fase investigatória, senão quando necessária a sua intervenção, sempre provocada pelos órgãos que atuam na investigação. O juiz das garantias não é um juiz investigador. Nesse sistema, a inércia do juiz em relação à persecução penal deve ser absoluta, não sendo possível a adoção de medidas que promovam ou incentivem a decisão de acusar, sob pena de quebra do princípio da imparcialidade objetiva (Cunha, 2020).

Após a conclusão do julgamento das ADI 6.298/DF, ADI 6.299/DF, ADI 6.300/DF e ADI 6.305/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgados em 24/08/2023 pelo plenário do STF, a normatividade desse dispositivo reatou ainda mais prejudicada.

A esse respeito Márcio André e Leonardo Barreto observam que *STF decidiu, por maioria, atribuir interpretação conforme ao art. 3º-A do CPP, para assentar que o juiz, pontualmente, nos limites legalmente autorizados, pode determinar a realização de diligências suplementares, para o fim de dirimir dúvida sobre questão relevante para o julgamento do mérito.*

*O Supremo abrandou, portanto, a proibição absoluta que a redação do art. 3º-A poderia sugerir.*³¹

A esse respeito, vejamos manifestação do STJ em 2025:

O magistrado pode acessar redes sociais de investigado e utilizar as informações públicas para fundamentar decisão de prisão preventiva e medidas cautelares, sem que isso configure violação ao sistema acusatório ou quebra de imparcialidade, desde que observados os limites legalmente autorizados.

³¹ <https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/de872154ffbf91a5dcc0e539dd2d5106?palavra-chave=6298&criterio-pesquisa=e>

Processo em segredo de justiça, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 1º/4/2025, DJEN 8/4/2025. ³²

A questão em discussão consiste em saber se a atuação do magistrado de acessar redes sociais de investigado e utilizar as informações públicas para fundamentar decisão de prisão preventiva e medidas cautelares configura violação ao sistema acusatório e quebra de imparcialidade.

Nesse contexto, não há ilegalidade na conduta do magistrado que, para decidir pedido feito pela acusação de prisão preventiva e medidas cautelares, observando referência do representante do Ministério Público à rede social de investigado, em exercício do livre convencimento motivado, realiza diligência suplementar consubstanciada em consulta pública para conferir a verdade dos fatos alegados.

Especificamente quanto ao fato de o magistrado ter realizado a consulta pessoalmente, tem-se medida de economia processual, diante da facilidade do acesso às informações públicas disponíveis em rede social. Ademais se o magistrado pode determinar a realização de diligências, nada obsta que possa fazê-las diretamente, em analogia ao contido no art. 212, parágrafo único, do CPP.

Esse entendimento está em consonância com o decidido pelo STF nas ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305 no sentido de que "Simultaneamente, remanesce a possibilidade de o juiz, de ofício: (a) "determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante" (artigo 156, II); (b) determinar a oitiva de uma testemunha (artigo 209); (c) complementar a sua inquirição (artigo 212) e (d) "proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição" (artigo 385)".

STJ, 2025 — protagonismo judicial na oitiva e necessidade de demonstração de prejuízo.

No AgRg no HC 935.026/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN 2/6/2025, o STJ afirmou que eventual protagonismo do magistrado na oitiva de testemunhas não conduz automaticamente à nulidade, exigindo-se demonstração do prejuízo.

Vedação absoluta de juiz assumir atividade investigativa.

1. A instauração de inquérito judicial por autoridade administrativa, como o Corregedor-Geral de Justiça, para apuração de ilícitos criminais, viola o princípio acusatório e o devido processo legal, sendo nula desde sua origem.

2. A atribuição para a persecução penal é exclusiva do Ministério Público e da autoridade policial, sendo vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação, conforme o art. 3º-A do Código de Processo Penal.

Processo em segredo de justiça, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 5/5/2026.

³²

<https://scon.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?acao=pesquisar&aplicacao=informativo&livre=%40CNOT%3D%27021690%27>

INICIATIVA DO JUIZ NA FASE PROCESSUAL.

Vejamos as disposições legais a esse respeito:

Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:

(...)

II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.

É importante observar que, na fase processual, o juiz seria dotado de **capacidade probatória suplementar**, para esclarecer fatos, circunstâncias ou elementos, destinados a esclarecer provas existente e já apontadas pelas partes, mas não para localizar novas fontes de prova.

A esse respeito, vejamos as lições apresentadas pelo professor Renato Marcão:

Já o inc. II permite determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. Na busca da verdade real, trata-se de mera faculdade conferida ao julgador, que apenas poderá agir de forma supletiva, visando tão somente a complementação da prova ou seu esclarecimento com o fim de dirimir dúvida, de modo que não se permite ao juiz suprir a inércia da parte ou a esta se sobrepor, tomando para si a iniciativa de produzir prova. A iniciativa probatória do juiz que atua no sistema acusatório encontra-se envolta por limites, de modo que não pode ganhar contornos de iniciativa acusatória [...] (Marcão, 2017).

Assim, é de se admitir a dúvida do juiz apenas sobre prova produzida, e não sobre a insuficiência ou a ausência da atividade persecutória (Pacelli, 2017).

O CPP possui diversos outros dispositivos que caminham nesse mesmo sentido, observe:

Art. 209. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes.

§ 1º Se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem.

Art. 212. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida.

Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição;

Art. 234. Se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, providenciará, independentemente de requerimento de qualquer das partes, para sua juntada aos autos, se possível.

Dessa forma, pode-se concluir que a iniciativa na produção probatória é atribuído às partes, cabendo ao magistrado somente a tarefa de suplementar a produção probatória e sanar dúvidas sobre pontos específicos.

Vejamos interessante julgado exarado pela 5ª Turma do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. EXPOSIÇÃO DE PERIGO À VIDA E À INTEGRIDADE FÍSICA DE DIVERSAS VÍTIMAS, MEDIANTE EXPLOÇÃO. INICIATIVA PROBATÓRIA DO JUIZ NO CURSO DO PROCESSO PENAL. ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA. DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, DA REALIZAÇÃO DE EXAME COMPLEMENTAR DE CORPO DE DELITO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 168, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE REAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "no curso do processo penal, admite-se que o juiz, de modo subsidiário, possa - com respeito ao contraditório e à garantia de motivação das decisões judiciais - determinar a produção de provas que entender pertinentes e razoáveis, a fim de dirimir dúvidas sobre pontos relevantes, seja por força do princípio da busca da verdade, seja pela adoção do sistema do livre convencimento motivado" (RHC n. 59.475/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 9/6/2015, DJe de 18/6/2015). 2. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, o art. 168 do Código de Processo Penal, expressamente, dispõe que se procederá a exame complementar por determinação da autoridade judiciária, de ofício. 3. Na hipótese dos autos, a determinação, no curso do processo penal, embora de ofício, da complementação de exame de corpo de delito já anexado aos autos, não se confunde com a hipótese na qual o magistrado substitui as partes no tocante à produção das provas. [...] (AgRg no RHC 119.112/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Observe que o tema foi objeto de cobrança na prova discursiva do tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul no ano de 2021, observe:

Em setembro de 2022, Ferdinando, investigado pelo crime de latrocínio, foi alvo de busca e apreensão da possível arma utilizada para o cometimento do crime, tendo a medida sido requerida pelo Ministério Público e deferida pelo Juiz, na fase inquisitorial. Após a conclusão das investigações, foi oferecida denúncia e teve curso a instrução criminal. Em fevereiro de 2023, após a instrução, e antes de proferir sentença, com vistas a dirimir dúvida sobre ponto relevante, o Juiz de ofício determinou a realização do exame de confronto balístico. Diante disso, a defesa técnica de Ferdinando arguiu, mediante exceção, a suspeição do Juiz alegando sua parcialidade com os seguintes fundamentos:

a) o Juiz não poderia funcionar na instrução, pois ele já tinha atuado na fase inquisitorial deferindo medida cautelar contra o acusado;

b) o Juiz não poderia determinar diligência de ofício (o exame de confronto balístico), que é prejudicial ao réu. Analise a exceção de suspeição oposta pela defesa técnica de Ferdinando.

O tema foi objeto de cobrança na prova para Promotor de Justiça do RJ no ano de 2026, vejamos:

Durante a instrução criminal de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face de Dionísio, em razão da prática do crime de latrocínio, o Juiz de ofício entendeu necessário ouvir Décio, testemunha que não tinha sido arrolada pelas partes, bem como Cláudio, pessoa à qual uma testemunha tinha feito referência. O Juiz proferiu sentença condenando Dionísio, com base nos depoimentos de Décio e Cláudio, tendo a defesa de Dionísio recorrido da condenação, alegando a parcialidade do Juiz. No julgamento do recurso de apelação, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça resolveu reinterrogar Dionísio e ouvir novamente as testemunhas Décio e Cláudio. Diante desse contexto, assinale a afirmativa correta.³³

(A) O Juiz não poderia ter determinado de ofício a oitiva das testemunhas Décio e Cláudio, pois isso implica violação ao seu dever de imparcialidade.

(B) O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação defensiva, não poderia proceder ao reinterrogatório de Dionísio, pois isso implica reformatio in pejus.

(C) O Tribunal de Justiça poderia proceder ao reinterrogatório de Dionísio, mas o Juiz não poderia ter determinado de ofício a oitiva das testemunhas Décio e Cláudio.

(D) O Juiz poderia ter determinado de ofício a oitiva das testemunhas Décio e Cláudio, e o Tribunal de Justiça poderia proceder à oitiva das mesmas testemunhas.

(E) O Juiz poderia ter determinado de ofício a oitiva das testemunhas Décio e Cláudio, não podendo o Tribunal de Justiça proceder à nova oitiva das testemunhas.

O tema também foi cobrado na prova para Procurador da UERJ no ano de 2025, vejamos:

Ano: 2025 Banca: UERJ Órgão: UERJ Prova: UERJ - 2025 - UERJ - Procurador

De acordo com a jurisprudência do STF, no tocante à atuação do juiz, é correto afirmar que o(a):³⁴

A juiz não pode proferir sentença condenatória, quando o MP tiver opinado pela absolvição em suas alegações finais

B inobservância do prazo de 24 horas, previsto em lei, para a promoção da audiência de custódia pelo juiz, implica a ilegalidade automática da prisão

C consagração do sistema acusatório transforma o juiz em protagonista do processo, permitindo a substituição da atuação probatória do órgão de acusação

D art. 3º-A do Código de Processo Penal (CPP) deve ser interpretado de modo a vedar a substituição de qualquer das partes pelo juiz, sem impedir que, pontualmente, nos limites legalmente autorizados, aquele determine a realização de diligências voltadas a dirimir dúvida sobre ponto relevante

³³ Gabarito: D.

³⁴ Gabarito: D

Por fim, uma questão de prova tem sido constantemente questionada por parte da FGV: MPE/Paraná/2026:

“Em matéria de provas, responda fundamentadamente:
I – Qual a distinção entre o ‘contraditório para a prova’ e o ‘contraditório sobre a prova’, indicando exemplo de cada situação. (0,6 ponto)
II – É cabível ao juiz das garantias ordenar, de ofício, antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, nos termos do art. 156, inciso I, do Código de Processo Penal? (0,4 ponto)”

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DAS PROVAS.

São 03 os possíveis sistema de avaliação / valoração da prova:

Sistema da íntima convicção.

Sistema da prova tarifada, tarifária ou tarifado.

Sistema do convencimento motivado ou da persuasão racional do juízo.

SISTEMA DA ÍNTIMA CONVICÇÃO.

Trata-se do sistema em que o juiz é absolutamente livre para decidir conforme as suas convicções pessoais, sem a necessidade de motivação.

Não foi o sistema ordinariamente adotado pelo ordenamento jurídico, essencialmente, se consideramos as disposições contidas no artigo 93, IX, Constituição Federal, vejamos o texto legal:

Art. 93.

(...)

IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

Apesar de não ser a regra em nosso ordenamento, **o referido princípio foi adotado excepcionalmente no âmbito dos tribunais do júri e deriva da soberania e sigilo inerente às decisões emitidas pelo tribunal do júri.**

Renato Brasileiro relata que “se fosse o jurado obrigado a fundamentar sua decisão, seria possível identificar-se o sentido de seu voto. Daí a desnecessidade de fundamentação do voto do jurado, limitando-se o mesmo a um singelo “sim” ou “não” para cada quesito que lhe for formulado, nos exatos termos do art. 486, caput, do CPP”. (Lima, 2017).

SISTEMA DA PROVA TARIFADA.

Também pode ser chamado de sistema da prova legal, da certeza moral do legislador, da verdade legal e da verdade formal.

Nesse sistema, não há liberdade ao julgador, considerando que a própria Lei atribui valores às provas de modo que ao magistrado somente resta o exercício da atividade matemática.

De acordo com FERNANDO CAPEZ, “não existe convicção pessoal do magistrado na valoração do contexto probatório, mas obediência estrita ao sistema de pesos e valores imposto pela lei” (Capez, 2018).

Nos dizeres de PAULO RANGEL: “Em verdade, o sistema das regras legais é a desconfiança que o legislador tem do juiz. Estabelece-se, assim, a certeza moral do legislador. Em termos de provas, não vale mais o que o juiz diz, mas, sim, o que o legislador estabelece como meio de prova prioritário.

Trata-se de sistema que foi adotado somente a título de exceção em nosso ordenamento jurídico, conforme se extrai da leitura do dispositivo a seguir:

Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Mitigação à tarificação de Provas:

À luz do sistema da persuasão racional e da interpretação do art. 167 do CPP, admite-se a mitigação da exigência de prova pericial, na hipótese de desaparecimento dos vestígios, bem como, em caráter excepcional, quando o conjunto probatório, dotado de elevada confiabilidade, coerência e convergência, revela-se apto a demonstrar, de forma cabal e inequívoca, a materialidade delitiva, desempenhando função probatória equivalente à da perícia técnica, cuja realização se mostre meramente confirmatória ou redundante.

Processo em segredo de justiça, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 10/6/2026, DJEN 17/6/2026.

Também podemos analisar certa tarificação nas disposições contidas no artigo 62 e 155, §único, vejamos:

Art. 62. No caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito, e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade.

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. [\(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008\)](#)

Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. [\(Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008\)](#)

O tema foi objeto de cobrança no ano de 2024 na prova de Promotor de Justiça do Estado de Santa Catarina, vejamos:

() O Código Penal de 1890, ao tratar do crime de adultério, estabelecia que “contra o corréu adúltero não serão admissíveis outras provas senão o flagrante delito, e a resultante de documentos escritos por ele”. Pode-se dizer que se trata de um exemplo de adoção do sistema tarifado de provas.

SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.

Trata-se do sistema adotado como regra em nosso ordenamento jurídico. Atribui certa liberdade ao magistrado para decidir, sempre pautado em premissas legalmente estabelecidas.

Nesse sentido, esclarece NESTOR TÁVORA (Távora, 2017):

Nele o juiz formará livremente a sua convicção, apreciando o conjunto probatório e valorando racionalmente os elementos de prova independentemente de qualquer tarifação legal. Deve, no entanto, fundamentar as suas decisões, pautando-as nos elementos que foram carreados aos autos, [...]. Com efeito, a própria Constituição Federal dispõe que os julgamentos dos órgãos judiciários serão fundamentados, sob pena de nulidade (art. 93, IX), enquanto o Código de Processo Penal assegura ao juiz a liberdade na apreciação da prova produzida sob a égide do contraditório, sendo-lhe vedado apoiar-se exclusivamente na prova colhida na fase de investigação, ressalvadas as hipóteses de provas cautelares, provas irrepetíveis e provas antecipadas (art. 155, caput, do CPP).

Renato Brasileiro aponta 03 características basilares, referente ao sistema da íntima convicção do juiz:

não há prova com valor absoluto.

deve o magistrado valorar todas as provas produzidas no processo, mesmo que para refutá-las.

somente serão consideradas válidas as provas constantes do processo.

O tema foi recentemente, no ano de 2024, cobrado na prova para Delegado de Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, vejamos:

Ano: 2024 Banca: [FGV](#) Órgão: [PC-SC](#) Prova: [FGV - 2024 - PC-SC - Delegado](#)

“O convencimento não deve ser, em outros termos, fundado em apreciações subjetivas do juiz; deve ser tal que os fatos e provas submetidos a seu juízo, se o fossem desinteressados ao de qualquer outro cidadão razoável, deveriam produzir, também neste, a mesma convicção que naquele”.

MALATESTA, Nicola Framarino Del. A Lógica das provas. Bookseller, 1996, vol. 13^a ed. (1912), p. 51.³⁶

Quanto ao sistema geral de avaliação das provas aplicado ao processo penal, encontra-se o relacionado

Alternativas

³⁵ Gabarito: C

³⁶ Gabarito: C

- à identidade física do juiz, no qual exige a presença física do magistrado, presidindo a instrução e avaliando todas as provas apresentadas pelas partes.
- ao sistema misto, pois impede que o juiz tenha iniciativa na fase de investigação, abrangendo a impossibilidade de se insurgir contra o arquivamento manejado pelo titular da ação penal.
- à persuasão racional, como regra. O magistrado tem ampla liberdade na valoração das provas, mas não é dado ao juiz fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, exceto no caso de provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
- à certeza moral do juiz, nos casos relacionados às decisões do juiz presidente e a dos jurados do Tribunal do Júri, as quais não precisam ser fundamentadas.
- à íntima convicção, como regra. É permitido ao juiz valorar as provas com ampla liberdade, decidindo de modo a aplicar o direito objetivo, a partir da sua convicção, sem a necessidade de submeter-se a um sistema tarifado.

PRINCÍPIOS RELATIVOS À PROVA PENAL.

Trataremos agora especificamente do tema princípios o correlacionando com o tema, provas.

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.

O princípio da proporcionalidade, tratado por alguns até mesmo como postulado relacionado a todo o campo do direito, ganha relevo em relação à diversos temas relacionados à prova.

PROPORCIONALIDADE E PROVA ILÍCITA PRO REO.

Conforme é pacífico no âmbito legal e doutrinário, não é possível o uso de provas ilícitas no processo.

Estabelece o art. 5º, LVI da CF:

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;

Contudo, parte considerável da doutrina permite, diante de situações concretas, a utilização de provas ilícitas, em determinadas situações, em benefício da defesa. Contudo, não se trata de uso indiscriminado dessas provas, trata-se, na verdade, de cotejar bens jurídicos de envergadura elevada e, diante de uma situação concreta, dar prevalência a um em detrimento de outro.

Imagine que estejam em rota de colisão a liberdade de locomoção de um inocente e a vedação à utilização de provas ilícitas. Justamente, nessas hipóteses, a doutrina tem admitido a utilização de provas ilícitas em benefício do réu, quando a sua utilização não consistir também em mais grave violação de direitos humanos.

Vejamos as relevantes lições apresentadas por **Paulo Rangel**:

*A regra do inciso LVI do art. 5º da CRFB não é, assim, nem poderia ser, absoluta. Deve ser interpretada de forma coerente e razoável, mostrando proporção entre os bens jurídicos que se contrastam. [...] Nesse sentido, surge em doutrina a **teoria da exclusão da ilicitude**, capitaneada pelo mestre AFRÂNIO SILVA JARDIM, à qual nos filiamos, onde a conduta do réu é amparada pelo direito e, portanto, não pode ser chamada de ilícita. O réu, interceptando uma ligação telefônica, sem ordem judicial, com o escopo de demonstrar sua inocência, estaria agindo de acordo com o direito, em verdadeiro **estado de necessidade justificante**. [...] Dessa forma, é admissível a prova colhida com (aparente) infringência às normas legais, desde que em favor do réu para provar sua inocência, pois absurda seria a condenação de um acusado que, tendo provas de sua inocência, não poderia usá-las só porque (aparentemente) colhidas ao arrepio da lei (Rangel, 2018).*

O tema foi cobrado na prova discursiva para o cargo de Juiz de Direito do Estado do Goiás no ano de 2022, vejamos:

O réu estava sendo processado pelo crime de roubo, art. 157, do Código Penal Brasileiro. Objetivando a comprovação da sua inocência dessa imputação, já que estava em outro lugar no momento do fato, subtraiu para si a filmagem do circuito interno de televisão da residência da sua amante, demonstrando o seu álibi. Como deve proceder o magistrado em relação à juntada dessa prova nos autos da ação penal, observado o disposto pelo art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal?

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E PROVA ILÍCITA PRO SOCIETATE.

Alguns doutrinadores posicionam-se no sentido de que a prova ilícita poderia ser utilizada mesmo que em favor da sociedade naquelas situações em que o **Estado se encontra em situação de vulnerabilidade frente à criminalidade**, por exemplo, nas hipóteses de organizações criminosas.

Trata-se de posicionamento de vanguarda e, ainda, com pouca repercussão jurídica, contudo é importante se conhecer essa vertente doutrinária:

Renato Brasileiro, com base nos ensinamentos de Barbosa Moreira, realiza os seguintes apontamentos:

Segundo BARBOSA MOREIRA, a aplicação do princípio da proporcionalidade também autoriza a utilização de prova ilícita em favor da sociedade, como, por exemplo, nas hipóteses de criminalidade organizada, quando esta é superior às Polícias e ao Ministério Público, restabelecendo-se, assim, com base no princípio da isonomia, a igualdade substancial na persecução criminal (Lima, 2017).

PRINCÍPIO DA COMUNHÃO DA PROVA.

Este princípio revela que as provas produzidas na marcha processual pertencem ao processo e não às partes que as produziram. Disso se pode extrair que **as provas não tem**

donos, mas meros proponente de modo que podem ser utilizadas para confirmar ou infirmar a versão de qualquer das partes.

Segundo EDILSON MOUGENOT BONFIM, “por esse princípio, a prova produzida pelas partes integra um conjunto probatório unitário, podendo favorecer a qualquer dos litigantes” (Bonfim, 2013).

O tema foi cobrado na Prova de Promotor de Justiça do Estado do Mato Grosso, vejamos a questão adaptada:

() Rege a produção probatória no sistema processual penal brasileiro os seguintes princípios: princípio do contraditório, princípio da comunhão da prova, princípio da oralidade, princípio da autorresponsabilidade das partes e princípio da não autoincriminação.³⁷

PRINCÍPIO DA AUTORRESPONSABILIDADE DAS PARTES.

Inicialmente, é importante observar que, baseado em diversas questões de política criminal, fora estabelecido o ônus de cada uma das partes integrantes da relação processual. Desse modo, **as partes são inteiramente responsáveis pelos seus comportamentos dentro da relação processual.**

“Conforme a distribuição do ônus da prova, cabe a cada parte dele desincumbir-se, e, se assim não proceder, arcará com as consequências que disso decorrem” (Marcão, 2017).

Bem ilustrando o princípio em comento, AVENA exemplifica:

Logo, se na ação penal pública não providenciar o Ministério Público a prova da autoria da infração e de sua materialidade, a consequência será a absolvição do acusado. Por outro lado, nada impede o juiz de utilizar, como fator de condenação, o testemunho de pessoa que, apesar de arrolada pela defesa, tenha contribuído para incriminar o réu, em vez de beneficiá-lo (Avena, 2017).

PRINCÍPIO DA ORALIDADE.

A oralidade é vista como uma das **vigas mestras na condução do processo penal brasileiro**, busca-se dar **prevalência à palavra falada em detrimento da escrita**. Com esse comportamento, almeja-se celeridade ao desenvolver processual.

Essa conduta pode ser vista até mesmo na forma pela qual se tratavam os debates no âmbito da instrução processual: debates orais.

Vejamos alguns dispositivos no âmbito do Código de Processo Penal:

*Art. 403. Não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, serão oferecidas **alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo** o juiz, a seguir, sentença. [\(Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008\).](#)*

(...)

§ 3º O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. Nesse caso, terá

³⁷ Gabarito: C

Parte considerável da doutrina aponta 03 subprincípios da oralidade:

- Princípio da **concentração**.
- Princípio da **imediaticidade**.
- Princípio da **identidade física do juiz**.

Vejamos cada um deles separadamente:

SUBPRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO.

Busca-se com esse princípio a realização de uma **única audiência destinada a produção probatória, desde que isso seja possível**. Caso não seja possível, a instrução deve ser realizada no menor número possível de audiências, fala-se, por essa razão, em audiência una.

Vejamos os dispositivos legais que confirmam esse posicionamento:

Art. 400.

(...)

§ 1º As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

Norberto Avena caminha no seguinte sentido ao relatar que o critério de condução do processo, já inserido em diplomas legais, como a Lei 9.099/1995 (art. 81), foi incorporado ao Código de Processo Penal pela Lei 11.719/2008, ao estabelecer, nos arts. 400, 411 e 431 (procedimento ordinário, rito do júri e procedimento sumário, respectivamente), a concentração das provas orais em audiência única de instrução (Avena, 2017).

SUBPRINCÍPIO DO IMEDIATISMO OU DA IMEDIATICIDADE.

Este princípio apregoa que **as provas devem ser produzidas perante a autoridade judiciária, a qual deve manter contato direto com a prova a fim de que possa avaliar, conforme o seu juízo, o nível de veracidade que as informações lhe imprimem**.

Avena relata que é “necessário assegurar ao juiz o contato físico com as provas no ato de sua obtenção, inclusive para que possa ele conservar em sua memória aspectos importantes do momento em que tenham sido aquelas provas produzidas e, desse modo, valorá-las com maior exatidão no ato da sentença” (Avena, 2017).

Nesse sentido, caminha o artigo 217, CPP, vejamos a literalidade do dispositivo:

Art. 217. Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor.

SUBPRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ.

Trata-se de princípio que conta com previsão legal, vejamos as disposições contidas no art. 399, § 2º do CPP:

Art. 399.

(...)

§ 2º O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença.

Esse princípio orienta que o juiz que presidiu a instrução, deverá, em regra, proferir a sentença. Logicamente, desde que isso seja possível. Em determinadas hipóteses, não será possível que o juiz responsável pela instrução seja o juiz sentenciante, como naquelas hipóteses de afastamento do magistrado, promoção à 2ª instância ou mesmo nos casos de óbito ou doença incapacitante.

PRINCÍPIO DA LIBERDADE PROBATÓRIA.

Os **direitos envolvidos no âmbito do processo penal são extremamente valiosos**. De um lado encontra-se a pretensão punitiva estatal, a qual representa interesses de toda a coletividade, do outro encontra-se o direito de liberdade do acusado, o qual somente pode ser restringido em situações excepcionais e pontuais.

Justamente por essa razão, a amplitude probatória no processo penal é uma realidade. **As partes gozam de ampla liberdade na produção de provas, sofrendo limitações pontuais em decorrência de imposições também de índole legal**. Essa **limitação decorre de resquícios da tarifação de determinados meios de prova**, como por exemplo nas exigências de que “somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil”, e no art. 158, ambos do CPP, que, a seu turno, determina que nas situações em que o delito deixar vestígios será indispensável o exame de corpo de delito direto ou indireto. A liberdade probatória diz respeito à produção de provas lícitas (Marcão, 2017).

Fala-se em liberdade probatória em 03 perspectivas distintas:

- Quanto ao momento de sua produção.
- Quanto ao tema da prova.
- Quanto ao meio de produção.

QUANTO AO MOMENTO DA PRODUÇÃO DA PROVA.

Apesar de existir um momento específico para a produção probatória, a fase da instrução processual, é possível sua produção em outros momentos processuais. Essa premissa pode ser extraída a partir da leitura do artigo 231, CPP, vejamos a literalidade do dispositivo:

Art. 231. Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo.

Logicamente, há exceções no ordenamento jurídico, como se observa da literalidade dos artigos 41, 396-A e 479, CPP, vejamos a redação:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Renato Brasileiro também aponta limitações no âmbito do tribunal do júri, vejamos:

Segundo esse dispositivo, durante o julgamento no júri não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte. Compreende-se na proibição desse artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados (Lima, 2017).

LIBERDADE QUANTO AO TEMA DA PROVA.

Todos os **temas relevantes para a decisão podem ser objeto de prova**. Às partes são dotas de liberdade para provar suas alegações, apontando o esforço probatório livremente para os fatos que confirmem a sua versão ou infirmem a versão contrária.

LIBERDADE QUANTO AO MEIO DE PROVA.

Não vigora no processo penal um sistema taxativo de provas. As partes são relativamente livre para adotar qualquer meio de prova, mesmo aqueles não previstos taxativamente no âmbito do Código de Processo Penal.

Fala-se relativamente livre, em razão de a própria legislação limitar certos tipos de provas para certas matérias no âmbito processual.

O CPC possui dispositivo bastante elucidativo a esse respeito, vejamos:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

PROVA VEDADA / ILEGAL.

O tema foi cobrado na prova discursiva DPE-SC – Analista Jurídico – FUNDATEC – 2025:
Elabore um texto de acordo com a proposta abaixo:

Em processo penal, o juiz ou a juíza poderá formar a sua convicção pela livre apreciação da prova. Contudo, há limitações a essa amplitude de convencimento, dentre as quais está a temática das provas ilícitas. Considerando a temática apresentada, estruture seu texto com base no que segue:

- a) Defina e explique o que são as provas ilícitas no processo penal.
- b) Fundamente sua resposta e indique as consequências legais do reconhecimento de uma prova como ilícita.
- c) Explique a relação entre prova ilícita e prova derivada da ilícita, bem como se existe exceção à inadmissibilidade de provas ilícitas no processo penal.

Estudamos no tópico anterior que vigora no ordenamento jurídico brasileiro a liberdade probatória. Contudo, essa liberdade não é plena e ilimitada, pelo contrário, sofre restrições de diversas espécies tanto no campo constitucional quanto no campo legal.

No âmbito da Constituição Federal, analisaremos a vedação à prova ilícita, a qual encontra respaldo no art. 5º, LVI, CF:

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;

MARINONI & ARENHART explicam que o constituinte fez uma opção em vedar a utilização das provas ilícitas no âmbito processual, dando prevalência a proteção do direito material envolvido em detrimento da obtenção da verdade.

A esse respeito, os renomados autores relatam:

*“com efeito, dita limitação não encontra fundamento no processo, mas sim na efetividade da proteção do direito material. Ou seja, tal norma constitucional proibiu a prova ilícita para dar maior tutela ao direito material, negando a possibilidade de se alcançar a verdade a qualquer custo. Diante disso, **é inegável que houve uma opção pelo direito material em detrimento do direito à descoberta da verdade.***

Guilherme Madeira, no âmbito de seu trabalho, levanta o seguinte questionamento:

Não seria melhor aceitar uma prova ilícita, na pretensão de descobrir a verdade, e apenas punir aquele que a produziu de forma ilícita³⁸?

O renomado autor relata que, ao se analisar o contexto histórico, observa-se que o Estado se mostrava complacente com aqueles agentes que produziam as provas ilícitas e não os responsabilizava, fenômeno que fomentava a atuação ilícita do Estado na atuação probatória.

Renato Brasileiro esclarece que o Estado não pode se valer de meios ilícitos de coleta de prova, violadores de direito, sob a alegação de elucidar fatos ilícitos. Seria, no mínimo, contraditório, que o Estado agisse ilegitimamente para combater atos ilícitos.

No Brasil, durante muito tempo vigorou nessa matéria o que **RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO** denominou “**princípio da veracidade da prova**”, segundo o qual a prova era analisada pela carga de convencimento que continha, abstraída a forma de sua obtenção; eventual irregularidade era vista como matéria de ilícito administrativo ou penal, a ser apurada em órbita própria, sem repercussão em sua admissibilidade (Moura, 2008).

PROVA ILÍCITA.

Trata-se de tema recorrente em provas de concursos públicos. O referido assunto tem origem na **Suprema Corte Norte Americana**, chamada **de princípio da exclusão ou regra da exclusão (exclusionary rule)**, corresponde ao princípio da inadmissibilidade de provas ilícitas no ordenamento jurídico brasileiro.

³⁸ Trata-se de reação ao “male captum bene retentum” (em tradução livre, “mal colhida, bem conservada”)

DISTINÇÃO ENTRE PROVAS ILÍCITAS E ILEGÍTIMAS.

A doutrina majoritária é enfática em diferenciar as provas ilícitas das ilegítimas. Tentamos consolidar as lições apresentadas pelo professor Gabriel Denzem, Renato Brasileiro e Antônio Magalhães Gomes Filho.

Os referidos autores inserem as duas espécies em um gênero: provas **ilegais ou vedadas**. As provas ilegais podem ser classificadas em dois grandes grupos: provas ilícitas e provas ilegítimas. Vejamos no quadro abaixo as diferenças apontadas pela doutrina:

<u>Distinção.</u>	
<u>Provas ilícitas.</u>	<u>Provas ilegítimas.</u>
Obtidas com violação de direito material.	Obtidos com violação de direito processual.
Violação na forma de colheita.	Violação na forma pela qual se produz a prova.
Em regra, são produzidas antes e fora do processo.	Em regra, produzidos durante o processo.
Efeito: Inadmissibilidade. □ Desentranhamento.	Efeito: Nulidade. □ irregularidade, nulidade absoluta ou nulidade relativa.
Não convalidáveis.	Podem ser renovadas se sanado o vício.

Apesar de toda a construção doutrinária nesse sentido, o CPP não acompanhou a diferenciação doutrinária, ocasião em que apresentou a seguinte disposição legal:

Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

A pergunta que surge a partir da leitura do artigo 157 é a seguinte:

A previsão do Código de Processo Penal acabou com a distinção entre provas ilícitas e provas ilegítimas?

A esse respeito, duas correntes se formaram:

- 1º Corrente □ Mesmo após a edição da Lei 11.690/2008, a qual incluiu a redação atual do artigo 157, CPP, deve ser mantida a distinção entre provas ilícitas e ilegítimas, considerando a diferenciação dos efeitos de uma e outra modalidade de prova vedada. É o posicionamento de ANTONIO SCARANCE FERNANDES e de PAULO RANGEL e DEZEM.
- 2º Corrente □ Aponta que não deve mais existir a diferenciação entre provas violadoras de normas constitucionais materiais ou processuais, ambas devem ser

consideradas como ilícitas. É a posição de GUSTAVO BADARÓ, que passou a definir prova ilícita como “as provas obtidas, admitidas ou produzidas com violação das garantias constitucionais, sejam as que asseguram as liberdades públicas, sejam as que estabelecem garantias processuais”.

PROVA ILÍCITA E SUA ADMISSIBILIDADE.

Conforme analisamos anteriormente, há mandamento constitucional expresso no sentido de não ser admissível a utilização de provas ilícitas no âmbito processual. Por outro lado, não há direito absoluto, motivo pelo qual a doutrina aponta situações excepcionais que poderiam, diante do caso concreto, fundamentar a utilização de provas ilícitas.

Há situações em que a doutrina e a jurisprudência admitem o uso da prova ilícita. Algumas são aplicáveis no Brasil, outras são discutidas apenas no direito norte-americano. Novamente insisto no quanto já afirmado anteriormente: a regra é a não utilização da prova ilícita. Apenas em situações excepcionais é que se poderá admitir o seu uso sob pena de a regra constitucional tornar-se exceção” (Dezem, 2018).

Vejamos as situações.

EXCEÇÃO DA BOA-FÉ.

Tem sua gênese com o **Juíz White** no caso *Stone v. Powel* (1.976), o qual entendeu que não se deveria aplicar o princípio da exclusão naquelas situações que um agente policial atuasse de forma ilícita, porém crente que agia de acordo com a Lei (boa-fé). Nessas situações, o efeito dissuasivo da inadmissibilidade da prova ilícita não estaria presente, motivo pelo qual não deveria ser declarada a ilicitude da prova.

Desse modo, basicamente a referida exceção relata que não deve ser declarada a inadmissibilidade da prova quando existir:

Boa-fé.

Crença razoável na legalidade da conduta.

Não há referência à adoção desse sistema no ordenamento jurídico brasileiro.

EXCEÇÃO DE IMPUGNAÇÃO.

Também pode ser chamada de **limitação da mentira da imputação do imputado**. Não tem aplicação no ordenamento jurídico brasileiro.

Nos EUA, assim como no Brasil, o réu não é obrigado a falar, contudo, caso o faça, tem a obrigação de falar a verdade. Nessa situação, provas ilícitas, não poderiam fundamentar uma decisão, por outro lado, **poderiam ser utilizadas para demonstrar a mentira e a inconsistência do depoimento do réu.**

EXCEÇÃO DO ERRO INÓCUO.

Segundo THIAGO ANDRÉ PIEROBOM DE ÁVILA, a referida exceção teria aplicação em duas hipóteses:

Erros ou vícios sem nenhuma relevância prática que não ocasionem lesão significativa a direitos da parte.

Condenações fundadas em um conjunto probatório, ocasião em que somente uma delas é ilícita, assim, seria possível a sua retirada e, mesmo assim, a decisão poderia fundar-se em outras provas existentes.

Trata-se de hipótese reconhecida pela jurisprudência, apesar de não ter sido adotado o referido nome. Vejamos julgado citado na obra do professor DEZEM:

[...] A esse respeito, decidiu o STJ: 3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Independentemente da prova pericial tida por ilícita (teste de alcoolemia), há nos autos principais diversos depoimentos, inclusive do próprio paciente, admitindo a ingestão de bebida alcoólica anteriormente aos fatos, assim como dos socorristas e do médico quanto aos indícios de embriaguez, em razão do hálito etílico do ora paciente, além das testemunhas que informam que o acusado teria ingerido algumas garrafas de vinho juntamente com um amigo e deixado o restaurante conduzindo seu veículo Passat em alta velocidade e em aparente estado de embriaguez, elementos que não são derivados da prova pericial. Questão que deve ser submetida ao Conselho de Sentença para que forme o convencimento acerca do elemento subjetivo dos homicídios imputados". (STJ, HC 342.512/PR, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 29.03.2016)

EXCEÇÃO DA PROVA ILÍCITA PRO REO.

Já tratarmos preliminar do tema quando falamos da adoção do princípio da proporcionalidade.

Assim, a doutrina majoritária admite a utilização da prova ilícita “pro reo”. Contudo, a discussão não pode ser resolvida sem uma maior profundidade, explica-se melhor: quando tratamos da admissibilidade da prova ilícita, explicamos que há um confronto entre o direito a liberdade e a vedação à utilização de provas ilícitas. Nessa situação, não se deve considerar abstratamente o direito a liberdade, mas sim, concretamente.

Deve-se analisar se há risco real de restrição da liberdade, assim como deve-se analisar o direito violado com a obtenção da prova ilícita. A esse respeito, são preciosas as lições do professor Guilherme Madeira:

Quando PACELLI analisa a liberdade neste conflito de valores, faz a análise da liberdade em abstrato. No entanto, esta análise não nos parece a melhor. Não nos parece razoável, por exemplo, que se admita o uso de tortura para provar a inocência de alguém que seja acusado de crime contra a honra. Ora, a liberdade não pode ser analisada de maneira abstrata. É preciso que se analise de que tipo de liberdade se está a falar.

O tema já foi objeto de questionamento na prova subjetiva para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado de Goiás:

UEG - Delegado de Polícia (PC GO)/2013. Capitão Didi responde a processo por prática de crime previsto no artigo 157, § 2º, I, do Código Penal. Para comprovar sua inocência, subtrai um determinado documento da residência de Pé de Pano e tortura Paco para obter as gravações do dia do assalto, vindo a provar, com tal documento e com as gravações, que é inocente e que, na realidade, o autor do delito teria sido Pé de Pano. Analise, fundamentadamente, a validade das provas.

EXCEÇÃO DA VISÃO AMPLA / VISÃO ABERTA.

Trata-se de exceção aplicável especificamente em relação ao cumprimento de mandados de busca e apreensão. “Se a coisa estiver à vista ampla do policial então poderá ser apreendida sem necessidade de mandado judicial” (Dezem, 2018).

“Se no curso de diligência policial os policiais encontram item que esteja à vista aberta dos policiais, então poderão fazer a apreensão deste objeto ainda que ele não conste do mandado de busca e apreensão. Assim, se no curso de uma busca e apreensão os policiais encontram uma pistola com silenciador, poderão apreendê-la ainda que não conste do mandado” (Dezem, 2018).

A doutrina norte americana fixou as seguintes premissas para a aplicação da referida exceção:

- a) o objeto deve estar em plena vista do policial;
- b) o policial deve poder estar legalmente no local onde viu o objeto;
- c) a natureza das provas incriminatórias deve ser imediatamente aparente.

Renato Brasileiro diz que a ilicitude permanecerá nas seguintes hipóteses:

Quando o policial já tiver encontrado o objeto do mandado continuar a efetuar buscas no interior da residência.

Cumprimento do mandado em locais que não estavam contemplados no mandado.

O referido autor relata que não há precedentes judiciais da utilização dessa teoria, contudo alerta que ela muito se assemelha a teoria que trata do encontro fortuito de provas.

SERENDIPIDADE / ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS.

A serendipidade possui correlação bastante estreita com a teoria da visão ampla analisada no tópico anterior.

A teoria da serendipidade ou do encontro fortuito de provas naquelas hipóteses em que provas de determinada infração penal são encontradas a partir de diligências regularmente autorizadas para a investigação de outro crime.

A validade dessa prova está condicionada a licitude da diligência originária, se a diligência foi realizada de forma abusiva ou com desvio de finalidade, a prova encontrada de modo fortuito é inválida. Por outro lado, se o encontro foi, de fato casual, fortuito, não há nenhuma ilicitude e a prova é válida.

Vejamos interessante julgado do STJ que trata a respeito desse tema:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE

USO PERMITIDO. NULIDADE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO EM PROCEDIMENTO INSTAURADO PARA APURAÇÃO DE CRIME PRATICADO POR ESTAGIÁRIO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO ESPECÍFICA PARA O ADVOGADO. ILICITUDE DOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. CRIMES PERMANENTES. AUSÊNCIA DE REPRESENTANTE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. MERA IRREGULARIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - O recorrente é advogado e foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 c/c 12, da Lei n. 10.826/03, pois, em cumprimento a mandado de busca e apreensão no escritório do recorrente, expedido com o fim de apreender arma que pertenceria a estagiário do escritório, a polícia se deparou com aproximadamente 765 g (setecentos e sessenta e cinco gramas) de maconha e um revólver, calibre 38, além de 14 (quatorze) cartuchos íntegros numa caixa de metal.

II - Não obstante o mandado de busca e apreensão tenha sido expedido para apuração de crime praticado pelo estagiário do escritório do recorrente, verificou-se, no cumprimento da medida, a ocorrência flagrancial de dois outros crimes que possuem natureza permanente. Contraria a razoabilidade exigir-se dos policiais envolvidos na diligência que fingissem não ver os crimes, para solicitar, a posteriori, um novo mandado específico de busca e apreensão para o escritório do recorrente (Doutrina e jurisprudência).

III - A despeito da não indicação expressa de representante da OAB local para o acompanhamento da diligência, foi solicitado, pelos policiais nela envolvidos, que uma advogada, estivesse presente e acompanhasse o cumprimento do mandado de busca e apreensão no escritório do recorrente, o qual se dirigia contra o estagiário. Diligência que não se revela nula em sua execução, quando muito, meramente irregular. Recurso ordinário desprovido. (RHC 39.412/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 17/03/2015).

Vejamos outro julgado recente em que o STJ enfrentou o tema:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, "a", do Regimento Interno do STJ.

2. A parte agravante alega que não se aplica a Súmula 7/STJ e reitera argumentos de mérito recursal, pedindo o provimento do agravo regimental para que o recurso especial seja conhecido e provido.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento de mandado de prisão, que resultou no encontro fortuito de provas, configura nulidade na busca domiciliar e se a decisão monocrática incorreu em erro ao aplicar a Súmula 7/STJ.

III. Razões de decidir

4. O mandado de prisão expedido por autoridade competente autoriza o ingresso dos policiais no domicílio do réu durante o dia, independentemente de permissão específica ou consentimento do morador, conforme art. 293 do CPP.

5. O fenômeno jurídico da serendipidade, que ocorre quando uma medida judicial resulta fortuitamente na localização de indícios de outro crime, é admitido na jurisprudência, não configurando desvio de finalidade.

6. A inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. O mandado de prisão autoriza o ingresso em domicílio durante o dia, sem necessidade de permissão específica. 2. O encontro fortuito de provas durante o cumprimento de mandado de prisão não configura desvio de finalidade. 3. O reexame de fatos e provas é inviável em instância especial, conforme Súmula 7/STJ".

Processo: AgRg no AREsp 2905079/RS (2025/0124829-7) — Relator: Ministro Ribeiro Dantas — Órgão Julgador: T5 (Quinta Turma) — Julgamento: 05/08/2025 — Publicação/Fonte: DJEN — Data da Publicação: 19/08/2025.

O tema também já foi objeto de cobrança em provas subjetivas para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Goiás:

CS UFG - Defensor Público do Estado de Goiás/2014. Em que consiste o fenômeno jurídico da serendipidade? Explícite os casos em que a serendipidade vem sendo expressamente admitida pelo Superior Tribunal de Justiça no contexto de interceptações telefônicas.

Há interessante julgado emitido pelo STJ a respeito do encontro fortuito de provas e do “fishing expedition”, vejamos as informações retiradas do [HC 663.055-MT](#), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 22/03/2022:

Admitir a entrada na residência especificamente para efetuar uma prisão não significa conceder um salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (*fishing expedition*), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade.

O tema serendipidade foi recentemente cobrado na prova do TRF- 5ª Região, para o cargo de Juiz Federal, vejamos a questão adaptada³⁹:

() A serendipidade é admitida no ordenamento jurídico brasileiro, sendo válidas as provas encontradas relativas à infração penal desconhecida, ainda que não exista conexão ou continência com o crime originário, desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências.

() A serendipidade é admitida no ordenamento jurídico brasileiro, desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências, sendo inválida a prova descoberta se não houver conexão ou continência entre o crime originário e aquele encontrado.

Em outro importante julgado, o STF (1ª Turma), por unanimidade, considerou lícito o aproveitamento da delação premiada como meio de prova em crimes de associação criminosa (ainda que não haja a imputação do crime de organização criminosa). O colegiado também ressaltou que, ao analisar o caso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) havia deixado claro que as buscas e apreensões foram lastreadas em elementos autônomos, independentes **do material** produzido na colaboração premiada, e realizadas em endereços relacionados a outras pessoas investigadas.⁴⁰

Em seu voto, o relator da matéria, ministro Luiz Fux, citou o entendimento do STF de que os elementos de informação trazidos pelo colaborador a respeito de crimes não conexos ao objeto da investigação primária devem receber o mesmo tratamento dado à descoberta fortuita e a outros meios de obtenção de prova, como a busca e apreensão e a interceptação telefônica. Segundo Fux, seria absurdo e até um desleixo do magistrado se ele fechasse os olhos para a existência de ilícitos revelados na colaboração premiada. Para ele, não há, no caso, nenhuma ilicitude ou vedação ao aproveitamento das provas obtidas por esse meio.

Esse tema também foi cobrado na prova de Juiz Federal do TRF, 5ª Região no ano de 2025, observe:

()

TEORIA DOS CAMPOS ABERTOS. OPEN FIELDS DOCTRINE E PRIVATE SEARCHES DOCTRINE.

Trata-se de teoria também aplicável aos casos de cumprimento de mandados de busca e apreensão, especificamente naquelas hipóteses em que buscas são realizadas em áreas que não violam a privacidade do investigado. A ideia básica dessa teoria é a seguinte: **sempre que o particular puder efetivar buscas sem autorização judicial, o Estado também poderá fazê-lo.**

Sempre que **não** houver “*expectativa de privacidade*” não há que se falar em violação da intimidade caso sejam realizadas buscas nesse local.

A Suprema Corte dos EUA teve este entendimento. Para fazer esta análise foi desenvolvido um teste, dando origem à teoria das private searches. Por meio desse teste, foi possível perceber se havia a efetiva

³⁹ Item C/E.

⁴⁰ <https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=497103&tip=UN>

*expectativa de privacidade (neste caso não poderá ser usada a prova) ou não (neste caso poderá ser usada a prova). O teste consistiu em uma análise ampla da expectativa de privacidade, tanto do ponto de vista do indivíduo quanto da sociedade: **a) expectativa subjetiva de privacidade** – consiste na opinião do indivíduo de que possui, naquela situação, privacidade; **b) expectativa objetiva de privacidade** – consiste na expectativa de privacidade reconhecida pela sociedade. Assim, a análise é dupla. Em um primeiro momento questiona-se a expectativa de privacidade do ponto de vista do indivíduo fazendo-se a pergunta “o indivíduo crê gozar de expectativa de privacidade nesta situação?” Caso a resposta seja afirmativa passa-se a um critério objetivo: “A sociedade reconhece como legítima esta expectativa de privacidade do indivíduo?”*

TEORIA DO RISCO.

Essa teoria apregoa que devem ser admitidas as provas obtidas a partir de declarações ou informações prestadas pelo próprio investigado, que, pressupondo sigilo, presta informações incriminadoras que posteriormente são conhecidas pelos órgãos investigativos.

A ideia é a de que se o investigado assume o risco de prestar essas informações, ainda que acreditando no sigilo, essa assunção do risco pode justificar a utilização das informações por parte dos órgãos investigativos.

BRASILEIRO registra que, embora não tratando propriamente da teoria do risco, o Supremo tem precedentes no sentido da validade da gravação de conversas, pessoais ou por telefone, por um dos interlocutores – desde que não haja causa legal específica de sigilo ou de reserva de conversação. O que a Constituição Federal veda é a ‘interceptação’, com o que não se identifica o ato de gravação clandestina por um dos próprios interlocutores.

EXCEÇÃO DA RENÚNCIA DO INTERESSADO.

Essa exceção não tem aplicabilidade no ordenamento jurídico brasileiro, pois aqui se o morador consentir poderão ser realizadas buscas no interior de sua residência, o que não acontece nos EUA.

Assim, essa exceção apregoa se houve consentimento livre e válido por parte do morador, essa autorização poderia afastar a ilicitude da prova obtida.

EXCEÇÃO DA LIMITAÇÃO DA INFRAÇÃO CONSTITUCIONAL ALHEIA.

Também não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro, para essa teoria somente o titular do direito violado poderia alegar a ilicitude da prova. Dessa maneira, se determinado processo contivesse prova ilícita, obtida com a violação de direito de terceiro, esse elemento poderia ser utilizado e seria considerado lícito dentro daquela relação processual.

Referida teoria não tem acolhida no ordenamento pátrio. [...] *a inadmissibilidade das provas ilícitas tem por escopo não apenas a proteção dos direitos fundamentais do acusado, mas também o de impor ao Estado um comportamento ético, a fim de se respeitar os parâmetros constitucionais estabelecidos, especialmente para limitar o exercício do ius puniendi (Lima, 2018).*

EXCEÇÃO DA LIMITAÇÃO DA INFRAÇÃO POR PARTICULARES.

Também não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro. Parte da premissa de que a vedação a utilização de provas ilícitas tem por finalidade dissuadir os agentes estatais de agirem ilicitamente na obtenção de provas.

Dessa forma, caso a prova ilícita seja obtida com a atuação de particulares, não haveria qualquer ilicitude nesse elemento.

Vejamos as lições de Renato Brasileiro a esse respeito:

Como já dito, no Brasil, a vedação à admissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos tem como objetivo precípua a tutela dos direitos e garantias fundamentais. Portanto, no ordenamento pátrio, pouco importa quem tenha sido o agente responsável pela produção da prova ilícita - autoridade policial ou particular - em ambos os casos a prova deve ser considerada ilícita. Não por outro motivo, ao apreciar o RE 251.445/GO, concluiu o Supremo Tribunal Federal ser prova obtida por meio ilícito e, por isso, inadmissível, a resultante de furto realizado por menor em consultório odontológico. Foram subtraídas fotografias que, entregues à polícia, serviram para instruir inquérito policial e processo criminal (Lima, 2018).

PROVAS ILÍCITAS POR DERIVAÇÃO.

A ideia aqui é a seguinte: de nada adiantaria vedar a utilização de provas ilícitas, se não houvesse também a vedação que fosse utilizadas as provas derivadas **exclusivamente** da ilícitas.

As provas derivadas das ilícitas são tão maculadas, quanto as próprias provas ilícitas. O raciocínio é simples se a finalidade é dissuadir os agentes estatais de violarem a ordem jurídica na obtenção de provas, de nada adiantaria inadmitir as provas ilícitas e admitir aquelas que derivassem daquelas.

Fala-se aqui então na **teoria dos frutos da árvore envenenada**, a qual também teve surgimento no direito Norte Americano.

BRASILEIRO conceitua: “Provas ilícitas por derivação são os meios probatórios que, não obstante produzidos, validamente, em momento posterior, encontram-se afetados pelo vício da ilicitude originária, que a eles se transmite, contaminando-os, por efeito de repercussão causal” (Lima, 2018).

Já o professor Avena relata que: “Provas ilícitas por derivação são aquelas que, embora lícitas na própria essência, decorrem exclusivamente de uma outra prova, considerada ilícita, ou de uma situação de ilegalidade, restando, portanto, contaminadas”.

A referida teoria foi reconhecida no âmbito do direito processual penal brasileiro:

Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

*§ 1º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando **não evidenciado o nexo de causalidade** entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma **fonte independente das primeiras**.*

O tema foi recentemente cobrado em prova no ano de 2024, vejamos:

(Analista Judiciário - Área Judiciária – CNJ) A respeito dos atos de comunicação processual, de nulidades, de provas e do princípio do livre convencimento motivado, julgue o item a seguir, de acordo com o CPP.

() Admitem-se provas derivadas de prova ilícita quando aquelas puderem ser obtidas por fonte independente, caso em que o regular andamento da investigação criminal pode conduzir ao fato objeto da prova. ⁴¹

Contudo, deve-se observar o seguinte: a ilicitude por derivação somente acontece quando a prova obtida se originar **direta e exclusivamente da ilícita**. Pois, de outro modo, sempre que houvesse uma prova ilícita, todas as diligências posteriores seriam inúteis, já que estariam maculadas pela ilicitude originária.

Diante dessa evidência, a Corte Norte Americana passou a se debruçar sobre a análise de hipóteses em que, apesar da ilicitude de uma prova na relação processual, outros elementos livres e desconexos foram produzidos de forma lícita.

De ver-se, então, a necessidade de se imporem alguns limites à derivação da ilicitude, de modo a impedir que ela se transforme em sanção perpétua ao autor da prova ilícita, como se aquele erro configurasse um pecado original. Bem por isso, eventuais irregularidades na efetivação do ato prisional não terão qualquer relevância para a produção de provas em relação ao fato, não se aplicando, então, a regra da contaminação (Pacelli, et al., 2018).

MARINONI & ARENHART esclarecem: deixe-se claro, **antes de qualquer coisa, que a ilicitude da prova não contamina o fato a ser esclarecido**, podendo se ligar, no máximo, a outras provas. Porém, uma prova ilícita não contamina, como é lógico, todo o material probatório, pois nada impede que um fato seja provado através de provas lícitas que nada tenham a ver com a prova ilícita. A prova obtida de modo ilícito pode propiciar outra prova, que então estará contaminada, mas nada impede que o fato que se desejou demonstrar seja objeto de uma prova que com ela não tenha qualquer vinculação. Essa última prova não pode ser dita derivada da ilícita ou pensada como contaminada. Tal prova é absolutamente autônoma e independente.

Conforme já salientado anteriormente, o tema é frequente em provas:

(TRF 4) - Juiz Federal (TRF 4ª Região). Aborde a questão da prova ilícita: 1) hipóteses constitucionais e legais de vedação; 2) prova ilícita por derivação; 3) tratamento doutrinário e jurisprudencial à admissão da prova ilícita; 4) casuística: 4.1) prova

⁴¹ Gabarito: Correto.

ilícita pro reo; 4.2) validade ou não da utilização de informações reconhecidamente sigilosas, lícitamente obtidas em feito criminal (para processos disciplinares decorrentes do mesmo fato, ou em procedimentos investigatórios por outros crimes).

VUNESP - Defensor Público do Estado do Mato Grosso do Sul. As recentes suposições de “grampos telefônicos”, envolvendo pessoas públicas do mais alto escalão, têm novamente trazido à tona a polêmica sobre a colheita de provas no processo penal. Diante desse quadro, discorra sobre o tema.

TEORIA DA FONTE INDEPENDENTE.

O cerne da questão é o seguinte: **é uma teoria voltada para o aproveitamento da prova derivada.**

Se uma prova possui diversas fontes e somente uma delas é eivada de vícios da ilicitude, seria possível o aproveitamento da prova derivada.

De acordo com a referida teoria, “havendo duas fontes das quais pode ser obtida a prova, sendo uma admissível e outra ilícita, é de se considerar como admissível e não contaminada a prova derivada” (Dezem, 2018).

Se “o órgão da persecução penal demonstrar que obteve, legitimamente, novos elementos de informação a partir de uma fonte autônoma de prova, que não guarde qualquer relação de dependência, nem decorra da prova originariamente ilícita, com esta não mantendo vínculo causal, tais dados probatórios são admissíveis, porque não contaminados pela mácula da ilicitude originária” (Lima, 2018).

Pacelli cita o seguinte exemplo: Uma diligência irregular por meio da qual se apreenda um veículo roubado, por exemplo, não impede a validade dos testemunhos que tenham presenciado a sua subtração, antes da apreensão. Pode-se até impedir o depoimento do agente responsável pela apreensão – e também pelo vício da prova – mas não se pode recusar a absoluta validade de outras provas, sem relação com o ato ilícito da apreensão.

No final das contas, nessa situação, apesar de existir um liame entre a prova ilícita e a lícita, existem outros liames possíveis entre outras provas lícitas, o que se denomina de fonte independente.

TEORIA DA DESCOBERTA INEVITÁVEL.

Também pode ser chamada de **fonte hipotética independente.** Nessa situação a prova derivada seria inevitavelmente descoberta, pois seguindo os tramites de praxe em investigação já em curso, aquela informação invariavelmente seria descoberta.

Na exceção do descobrimento inevitável, se admite que a segunda prova deriva da ilícita, porém se entende que não há razão para reputá-la nula ou ineficaz. Isso porque a descoberta por ela constatada ocorreria mais cedo ou mais tarde. A lógica do salvamento da segunda prova está em que não há motivo para retirar eficácia de uma prova, que trouxe uma descoberta que muito provavelmente seria obtida. Dessa forma seria possível dizer que nem todos os frutos da árvore venenosa são proibidos, pois alguns podem ser aproveitados (Marinoni, et al., 2015).

Para parte considerável da doutrina, essa teoria fora prevista no âmbito do §2º do artigo 157, vejamos a redação do dispositivo legal:

§ 2º Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova

Nesse momento, um questionamento se faz necessário:

Seria possível que o legislador infraconstitucional limitasse a inadmissibilidade de provas ilícitas?

Sobre o tema, há duas correntes:

1º Corrente: Não seria possível que o legislador infraconstitucional admitir a prova ilícita por derivação, de modo que é inconstitucional a limitação apresentada no âmbito do artigo 157, § 2º, CPP. Nesse sentido, segundo ANTÔNIO MAGALHÃES GOMES FILHO, referido dispositivo subverte o espírito da garantia constitucional do art. 5º, LVI, devendo ser considerado inconstitucional.

2º Corrente: De outro lado, há respeitável corrente doutrinária segundo a qual, como o conceito de prova ilícita e o de prova ilícita por derivação são indeterminados, tanto a ampliação indevida de seu âmbito conceitual quanto sua restrição podem ser afastadas pelo juiz no momento de sua aplicação. Nessa linha, de acordo com FEITOZA, tanto se pode admitir limitações à teoria da prova ilícita por derivação, quanto entender, para garantir direito fundamental, no caso concreto, que a limitação deva ser afastada e a prova deva ser reconhecida como prova ilícita (Lima, 2018).

TEORIA DO NEXO CAUSAL ATENUADO.

A referida teoria ganhou diversos nomes no âmbito doutrinário: **teoria da contaminação expurgada, da conexão atenuada, vício diluído, tinta diluída, mancha purgada, vícios sanados, em inglês: “purged tainted limitation”**.

Trata-se de teoria que se aproxima da **fonte independente**, porém com ela não se confunde. De acordo com essa teoria, apesar da existência de nexo entre a prova originária lícita e a derivada, acontecimentos posteriores são capazes de apagar essa mancha a ponto de admitir a utilização da prova ilícita.

Nesse sentido, vejamos as lições apresentadas por Renato Brasileiro:

De acordo com essa limitação, não se aplica a teoria da prova ilícita por derivação se o nexo causal entre a prova primária e a secundária for atenuado em virtude do decurso do tempo, de circunstâncias supervenientes na cadeia probatória, da menor relevância da ilegalidade ou da vontade de um dos envolvidos em colaborar com a persecução criminal. Nesse caso, apesar de já ter havido a contaminação de um determinado meio de prova em face da ilicitude ou ilegalidade da situação que o gerou, um acontecimento futuro

expurga, afasta, elide esse vício, permitindo-se, assim, o aproveitamento da prova inicialmente contaminada (Lima, 2018).

Pode parecer um pouco chocante, mas as referidas teorias já foram objeto de cobrança na prova do Ministério Público do Estado do Goiás, vejamos:

MPE GO) - Promotor de Justiça (MPE GO). Limitações à prova ilícita por derivação (exceções às exclusionary rules). Conceitue as teorias abaixo relacionadas e discorra sobre sua aplicabilidade no ordenamento jurídico brasileiro: a) teoria da fonte independente (independent source); b) teoria do descobrimento inevitável (inevitable discovery); c) teoria dos vícios sanados, da tinta diluída ou limitação da mancha purgada (purged taint); d) teoria da proporcionalidade (balancing test); e) teoria da destruição da mentira do imputado; f) teoria do risco; g) teoria da doutrina da visão aberta (plain view doctrine); h) teoria da renúncia do interessado.

INUTILIZAÇÃO DA PROVA ILÍCITA.

O Código de Processo Penal possui dispositivo elucidativo a esse respeito:

Art. 157.

(...)

§ 3º Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente.

Observe que, de acordo com o dispositivo legal, a licitude ou ilicitude da prova será valorada incidentalmente no curso da marcha processual, não sendo necessário aguardar todo o desenvolver processual para que essa questão fosse resolvida somente no momento da sentença.

Até porque, se fosse necessário aguardar a decisão, muito provavelmente o julgador já se encontraria irremediavelmente influenciado pelas informações advindas da ilicitude da prova.

A dúvida que surge é a seguinte:

O juiz teria liberdade para desentranhar ou não a prova reconhecidamente ilícita e desentranhada obrigatoriamente deveria destruí-la?

A pergunta ganha relevância quando se analisa a hipótese excepcional de a prova ilícita ser utilizada em benefício do réu (*aplicabilidade do princípio da proporcionalidade*). A partir dessa divergência surgiram 03 correntes a respeito da interpretação desse dispositivo:

1ª Corrente □ Reconhecida a ilicitude, o juiz obrigatoriamente deveria desentranhar e inutilizar a prova ilícita.

2ª Corrente □ Reconhecida a ilicitude, o juiz teria liberdade para decidir a respeito do não desentranhamento ou desentranhando, decidir pela não inutilização.

3ª Corrente □ Reconhecida a ilicitude, o juiz obrigatoriamente deverá desentranhá-la, mas poderá decidir a respeito da inutilização ou não da prova.

INUTILIZAÇÃO DA PROVA ILÍCITA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DO JÚRI.

Pedimos vênia para transcrever as lições apresentadas pelo professor Renato Brasileiro:

Destarte, caso a prova ilícita tenha sido produzida ainda na primeira fase do procedimento do júri, deve o juiz sumariante, ao pronunciar o acusado, determinar o desentranhamento da prova ilícita, deixando de levá-la em consideração na sua decisão. Se, no entanto, a prova ilícita tiver permanecido no processo ou nele ingressar após a pronúncia, ocorrendo o julgamento pelos jurados, deverá o Tribunal, em sede de recurso de apelação ou habeas corpus, reconhecer a ilicitude da prova e, por consequência, determinar a anulação do julgamento, diante da impossibilidade de se avaliar o grau de influência da prova ilícita sobre os jurados (Lima, 2018).

JUIZ CONTAMINADO.

Trata-se de dispositivo com eficácia suspensa no âmbito do artigo 157, § 5º, CPP, vejamos:

§ 5º O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acórdão.

Ministro LUIZ FUX, em 22/1/2020, concedeu medida cautelar requerida nas ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e suspendeu, sine die, a eficácia (ad referendum do Plenário) desse parágrafo.

De início, anoto que a norma em tela é extremamente vaga, gerando inúmeras dúvidas. O que significa “conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível”? Significa apenas travar contato com a prova ou pressupõe que o juiz necessariamente tenha emitido algum juízo de valor sobre o material probatório? Como se materializaria a demonstração desse “conhecimento”? O juiz, após “conhecer” do conteúdo da prova, ainda poderá proferir decisões interlocutórias e presidir a instrução, ficando impedido apenas para a sentença, ou ficará impedido desde logo? A ausência de clareza do preceito é também capaz de gerar situações inusitadas. Imagine-se o juiz que, ao proferir a sentença, se depare com uma prova ilícita e a declare como tal. Nesse caso, ele interrompe a prolação da sentença e, em seguida, remete os autos ao juiz que o substituirá? Imagine-se, agora, que a câmara de um tribunal decida anular um processo por ilicitude da prova e determine o retorno dos autos à origem. Nesse caso, a câmara ficará impedida de julgar nova apelação? A vagueza do preceito e as inúmeras dúvidas que ele suscita, por si sós, colocam em dúvida sua constitucionalidade. Uma das facetas do princípio da legalidade, princípio basilar do Estado Democrático de Direito, é que as leis sejam editadas, tanto quanto possível e adequado, com precisão, de modo que sejam aptas a efetivamente orientar a ação individual. Desse modo, promove-se previsibilidade e, conseqüentemente, segurança jurídica. Assim, a utilização de fórmulas legislativas excessivamente vagas viola a segurança jurídica e o princípio da legalidade.